

- Expediente N.º: EXP202205208

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ANTECEDENTES.....	2
PRIMERO: Reclamación presentada.....	2
SEGUNDO: Traslado de la reclamación a la parte reclamada.....	3
TERCERO. Resolución de archivo.....	3
CUARTO. Recurso de reposición.....	3
QUINTO: Actuaciones previas de investigación.....	3
SEXTO: Inicio de procedimiento sancionador.....	5
SÉPTIMO: Alegaciones al acuerdo de inicio.....	5
OCTAVO: Propuesta de resolución.....	10
NOVENO: Alegaciones a la propuesta de resolución.....	10
DÉCIMO: Volumen de negocio.....	11
HECHOS PROBADOS.....	12
PRIMERO.....	12
SEGUNDO.....	12
TERCERO.....	12
CUARTO.....	12
QUINTO.....	13
SEXTO.....	13
SÉPTIMO.....	13
OCTAVO	13
FUNDAMENTOS DE DERECHO.....	13
I.Competencia.....	13
II.Procedimiento.....	13
III.Cuestiones previas.....	14
IV.Alegaciones de la parte reclamada.....	14
1.Caducidad de actuaciones.....	15
2.Supuesto de hecho del procedimiento.....	16
3.Competencia de la AEPD.....	18

3.Modelo de comercialización de tarjetas prepago. Encargado del tratamiento....	19
4.Inexactitud de los datos.....	34
5.Proporcionalidad de la sanción.....	36
V.Práctica de prueba propuesta.....	39
VI.Obligación. Artículo 5.1 d) RGPD.....	40
VII.Tipificación y calificación de la infracción.....	42
VIII.Sanción.....	42
IX.Adopción de medidas.....	43
RESUELVE:.....	44
PRIMERO:.....	44
SEGUNDO:.....	44
TERCERO:.....	44
CUARTO:.....	44

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO: Reclamación presentada

A.A.A. (en adelante, la parte reclamante) con fecha 15 de abril de 2022 interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La reclamación se dirige contra **XFERA MÓVILES, S.A.** con NIF **A82528548** (en adelante, XFERA).

Presenta reclamación por recepción de llamadas comerciales en su línea móvil *****TELÉFONO.1** que promocionan los servicios de YOIGO. Justifica la inscripción en la lista de exclusión publicitaria, de la línea receptora a través de una copia del correo electrónico de Verificación de Cuenta recibido el día 15 de diciembre de 2021 y una captura de pantalla que acredita el alta de la línea receptora.

Aporta varias capturas de pantalla del registro de llamadas entrantes que acreditan la recepción de las siguientes llamadas:

- Desde la línea llamante *****TELÉFONO.2** recibió llamadas los días 12/04/2022 a las 13:53 horas, 13/04/2022 a las 17:32 horas y 14/04/2022 a las 17:21 horas.

- Desde la línea llamante *****TELÉFONO.3** recibió una llamada el día 11/04/2022 a las 17:51 horas.
- Desde la línea llamante *****TELÉFONO.4** recibió llamadas los días 18/3/2022 a las 18:14 horas y 19/3/2022 a las 17:12 horas y 17:34 horas.

SEGUNDO: Traslado de la reclamación a la parte reclamada

De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), con fecha 06/05/2022 se dio traslado de dicha reclamación a XFERA, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos.

El traslado, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), fue recogido en fecha 13/05/2023 como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente.

Con fecha 14/06/2022 se recibe en esta Agencia escrito de respuesta indicando, en esencia, que XFERA se encuentra adherida a ADigital y realiza comprobaciones en todas sus campañas comerciales de Lista Robinson. Tal filtrado con Lista Robinson es exigido igualmente a todos sus distribuidores en modalidad Televenta que pudieran utilizar bases de datos propias ajenas a XFERA.

Afirma contar con una herramienta a través de la cual pueden obtener información de sus sistemas que les permitiría consultar si han impactado comercialmente a una numeración determinada. El resultado obtenido, afirma XFERA, en relación con la numeración indicada es que no hay resultados para llamadas. Esto querría decir que esta numeración no se ha incluido en ninguna acción comercial vía telefónica autorizada por dicho operador.

TERCERO. Resolución de archivo

Con fecha de 22/07/2022 esta Agencia dictó resolución de archivo de actuaciones. Ello debido a que *“Una vez analizadas las razones expuestas por la parte reclamada, que obran en el expediente, se ha constatado la falta de indicios racionales de la existencia de una infracción en el ámbito competencial de la Agencia Española de Protección de Datos, no procediendo, en consecuencia, la apertura de un procedimiento sancionador.”*

CUARTO. Recurso de reposición

La parte reclamante, en fecha 03/08/2022 interpuso recurso de reposición contra la mencionada resolución de archivo. Tras la tramitación del oportuno procedimiento, en el que se otorgó trámite de alegaciones a la parte reclamada, esta Agencia dictó resolución en la que se acordó la estimación del recurso, ordenando que se prosiga la tramitación de la reclamación. Con ello, esta se entendió admitida a trámite

QUINTO: Actuaciones previas de investigación

La Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos en

cuestión, en virtud de las funciones asignadas a las autoridades de control en el artículo 57.1 y de los poderes otorgados en el artículo 58.1 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), y de conformidad con lo establecido en el Título VII, Capítulo I, Sección segunda, de la LOPDGDD, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

Desde la Inspección de Datos se consultó el operador responsable de los tres números telefónicos desde los que se habrían realizado las llamadas:

- Número de teléfono *****TELÉFONO.4** Operador actual XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL
- Número de teléfono *****TELÉFONO.3** Operador actual XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL
- Número de teléfono *****TELÉFONO.2** Operador actual XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL

Se ha requerido información a XFERA para que facilitara los titulares de las citadas líneas aportando esta, en su contestación, la siguiente información

1. Datos de contacto y de identificación del titular del número de teléfono *****TELÉFONO.4** en marzo de 2022: **B.B.B. DNI ***NIF.2**
2. Datos de contacto y de identificación del titular del número de teléfono *****TELÉFONO.3** en abril de 2022: **C.C.C. DNI ***NIF.2**
3. Datos de contacto y de identificación del titular del número de teléfono *****TELÉFONO.2** en abril de 2022: **D.D.D. DNI ***NIF.3**

Se requirió nuevamente a XFERA para que facilitara información relativa a *“Si existía algún tipo de relación contractual para la realización de llamadas telefónicas comerciales con los titulares de las líneas así como la dirección postal de contacto”*, indicando los dicha entidad que, en relación con los titulares de las numeraciones indicadas y las fechas referidas, no existía vínculo contractual para la realización de llamadas telefónicas en ninguno de los tres supuestos referenciados.

Xfera Móviles únicamente conoce la dirección postal de contacto de **C.C.C.**, al que ha identificado como titular de la línea telefónica *****TELÉFONO.3**

Con ello, la Inspección requirió información a **C.C.C.** en la dirección facilitada manifestando este que la línea *****TELÉFONO.3** estuvo a su nombre con la compañía *****EMPRESA.1**, y solo durante los meses de abril a junio de 2022. Afirma así mismo que, revisando las facturas de estos meses, ha verificado que no se realizó ninguna llamada a dicho número desde la línea *****TELÉFONO.3**, y es más, desde esa línea durante el tiempo que estuvo a su nombre no se habría llegado a realizar ni una sola llamada, lo cual, afirma, imposibilitaría que se haya realizado dicha llamada. Aporta la factura completa del mes de abril de 2022 en la que no figura ninguna llamada realizada desde este número.

También niega expresamente haberse dedicado a hacer llamadas comerciales sin consentimiento de la persona a la cual se haya podido llamar, manifestando su extrañeza por esta reclamación.

En relación a la confirmación de las llamadas comerciales, se ha requerido al operador *****EMPRESA.2** que ratifique la existencia de llamadas efectuadas al número del reclamante (*****TELÉFONO.1**) desde las numeraciones y en las fechas descritas por este. desde los números *****TELÉFONO.4** recibió llamadas el 18/03/2022 a las 18:14 (rechazada), el 19/03/2022 a las 17:12 (4 sg) y a las 17:34, *****TELÉFONO.3** el día 11/04/2022 a las 17:51 y *****TELÉFONO.2** el día 12/04/2022 al las 13:53 (7 sg) el 13/04/2022 a las 17:32 (6 sg) el 14/04/2022 a las 17:21, manifestando la referida operadora que en relación a la solicitud de llamadas realizadas desde el número de teléfono *****TELÉFONO.4**, dado que las llamadas solicitadas son de un periodo superior a un año, no es posible facilitar dichos datos al tener el sistema informático un tiempo limitado de almacenamiento de doce meses según la Ley 25/2007, de Conservación de datos por los operadores de comunicaciones electrónicas.

La Inspección solicitó a la Agencia Tributaria que proporcionara la dirección fiscal de los otros dos titulares de las líneas telefónicas identificados por XFERA:

- **B.B.B., DNI ***NIF.2**
- **D.D.D., DNI ***NIF.3**

La AEAT contestó facilitando la siguiente información.

„

- Dirección fiscal **de B.B.B..** La búsqueda en el sistema de la Agencia Tributaria no ha dado resultados para el DNI indicado *****NIF.2**
- **Dirección fiscal de D.D.D..** La Agencia Tributaria cuenta en su base de datos con una persona física a la que le corresponde el DNI indicado *****NIF.3**. No obstante, el nombre y apellidos de dicha persona física no se corresponden con los indicados.

SEXTO: Inicio de procedimiento sancionador

Con fecha 4 de abril de 2024, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada, por la presunta infracción del Artículo 5.1.d) del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD.

SÉPTIMO: Alegaciones al acuerdo de inicio

Notificado el citado acuerdo de inicio conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), la parte reclamada presentó escrito de alegaciones en el que, en síntesis, manifiesta lo siguiente:

ALEGACIONES JURÍDICO-FORMALES

Caducidad del recurso de reposición interpuesto el 3 de agosto de 2022. La resolución estimatoria del recurso de reposición presentado frente a la resolución que acordó el archivo de la reclamación fue dictada transcurrido el plazo de un mes, produciéndose así una vulneración del artículo 25.1 b) de la LPACAP en relación con el artículo 124.2

de la misma norma. Por este motivo, debió ordenarse el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95 de la LPACAP.

Caducidad de las actuaciones previas de investigación. De forma subsidiaria, se considera que no se ha respetado el plazo previsto en el art. 67.2 de la LOPDGDD respecto de la duración de las actuaciones previas de investigación, puesto que el plazo de doce meses previsto venció el 15 de julio de 2023. A pesar de ello, no se dictó informe de actuaciones previas de investigación hasta el 1 de abril de 2024. Por ello, considera que se debiera haber declarado la caducidad del expediente y haber ordenado el archivo de las actuaciones, según establece el artículo 25.1 b) de la LPACAP.

ALEGACIONES JURÍDICO-MATERIALES. Bajo este epígrafe, la parte reclamada incluye diversas alegaciones:

Datos objeto de conservación

Conducta imputada a XFERA. De la lectura del acuerdo de inicio se desprende que la supuesta conducta infractora nada tiene que ver con las llamadas comerciales recibidas por el reclamante, sino por el hecho de haber proporcionado “datos inexactos con la titularidad de las líneas telefónicas requeridas”, de lo que se deriva una presunta infracción del artículo 5.1 d) del RGPD.

Discrepancia con los hechos narrados en el Acuerdo. Las líneas de teléfono en las que se ha detectado la discrepancia son de tipo prepago y fueron comercializadas bajo la marca “Lebara”. Al tratarse de líneas prepago, XFERA no necesita conocer los datos identificativos del titular/usuario de la tarjeta para prestar el servicio, recogiendo únicamente información personal a efectos de dar cumplimiento a la Disposición adicional única de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas.

Lebara es una de las marcas, de prepago, bajo las que presta servicios de telecomunicaciones la parte reclamada. No ofrece servicios “de contrato” sino, únicamente ofrece servicios “de tarjeta”, esto es, basados en la compra de tarjetas y bonos prepago. De ahí que muchas de sus líneas tengan una rotación muy alta. Esta aclaración resulta esencial para el presente procedimiento, debido a que la adquisición de una de estas tarjetas prepago es un negocio jurídico de compraventa, de tracto único, en el que una persona acude a un punto de venta, adquiere una tarjeta y la utiliza hasta que consume el saldo que contiene precargado. Agotado este saldo, puede optar por recargarlo (manteniendo la numeración) o por comprar una nueva tarjeta. Por ese motivo, la identidad del usuario es irrelevante para Lebara.

Por ello, la única información que XFERA gestiona de los clientes que adquieren las tarjetas prepago de Lebara son los previstos en la Disposición adicional única de la Ley 25/2007;

Conforme a esta Ley, y la referida Disposición: “los operadores de servicios de telefonía móvil que comercialicen servicios con sistema de activación mediante la modalidad de tarjetas de prepago, deberán llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran una tarjeta inteligente con dicha modalidad de

pago". "La identificación se efectuará mediante documento acreditativo de la personalidad, haciéndose constar en el libro-registro el nombre, apellidos y nacionalidad del comprador, así como el número correspondiente al documento identificativo utilizado y la naturaleza o denominación de dicho documento".

Documentación acreditativa

Señala la incorrección de la AEPD en la página 6 del Acuerdo, cuando afirma que "conforme a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, los operadores de estas redes y servicios están obligados a conservar el dato de la titularidad de las líneas telefónicas que asignen a sus usuarios"; esta afirmación, no es cierta en relación a los usuarios de tarjetas SIM en modalidad prepago, como los que nos ocupan en este procedimiento: XFERA conoce únicamente el de la persona que adquirió la tarjeta, y solo porque así se lo obliga la Ley 25/2007.

La norma establece que "la identificación se efectuará mediante documento acreditativo de la personalidad"; pero en ningún caso permite ni obliga a la obtención y conservación de una copia del documento de identidad del comprador. En este sentido se ha pronunciado también la AEPD.

Modelo de comercialización

Señala que las compañías de telecomunicaciones no son titulares de la inmensa mayoría de los puntos de venta que comercializan sus productos y servicios. En el caso de Lebara, esta marca ni siquiera tiene tiendas propias. En el caso que nos ocupa, las tarjetas prepago correspondientes a las líneas ***TELÉFONO.4 y ***TELÉFONO.2 fueron comercializadas a través de la plataforma de la entidad Fullcarga Ibérica S.L., (...).

Fullcarga comercializa libremente las tarjetas a través de su extensa red de distribución, formada por multitud de pequeñas empresas. Se somete, para ello, al código de conducta de XFERA, cuyas obligaciones se hacen extensivas a todos los establecimientos adheridos a su red.

El código de conducta prohíbe específicamente, entre otras acciones, "enviar el formulario de venta a través de la herramienta dispuesta al efecto con datos de venta incorrectos, falsos o incompletos del cliente final" y "obtener altas de forma irregular, suplantando la identidad del cliente y/o sus datos personales". En materia de protección de datos, Fullcarga se configura como encargada, entre otros, del tratamiento consistente en "la comercialización de tarjetas SIM (incluyendo la identificación e inclusión de datos en el Libro Registro)" (anexo 4 del contrato).

Consultada por mi representada, Fullcarga nos ha confirmado que ambas ventas las realizó un comerciante adherido a su red y con quien XFERA no mantiene relación directa, llamado **E.E.E.**, provisto de **DNI ***NIF.4** y con domicilio en *****DIRECCIÓN.1.**

Considera que XFERA no es responsable por los hechos que se le imputan. XFERA no es titular de los puntos de venta que comercializan las tarjetas prepago de la marca

“Lebara”. En la práctica, es cada punto de venta el encargado de cumplir con la obligación de recabar los datos de los clientes, a efectos de dar cumplimiento a la obligación de llevanza del libro-registro previsto en la disposición adicional única de la Ley 25/2007. Al no poder exigir a los clientes que aporten una copia de su documento identificativo a la hora de adquirir una tarjeta prepago, y no necesitar tratar sus datos personales para ninguna otra finalidad, XFERA no tiene la capacidad de verificar la exactitud de los datos recabados por los puntos de venta, y (por tanto) no puede ser considerada responsable por las inexactitudes cometidas por dichos negocios. Considera, por lo tanto, vulnerado el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, “LRJSP”), que establece que “solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas (...) que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa”.

Destaca que, desde un punto de vista contractual, el acuerdo firmado entre XFERA y la plataforma comercializadora de las tarjetas SIM (Fullcarga) sometía a esta segunda, y a su red comercial, a un código de conducta en el que se obligaban a “tomar las medidas oportunas que impidan que se activen altas de contrataciones” en las que consten “datos de venta incorrectos, falsos o incompletos del cliente final”, con elevadas penalizaciones en caso contrario.

Asimismo, entiende que XFERA ha implementado distintos procedimientos para la lucha contra el fraude, y ha trasladado instrucciones precisas a los puntos de venta sobre cómo recabar los datos de los interesados, de cara a su inclusión en el libro-registro que exige la Ley 25/2007. A estos efectos, desarrolla los controles implementados para detectar actuaciones fraudulentas o altas en las que no se haya seguido el procedimiento establecido. Entiende, por lo tanto, que si alguno de dichos puntos de venta desoye estas instrucciones, el artículo 28.10 del RGPD prevé que sea considerado responsable del tratamiento.

Competencia de la AEPD

Señala una posible vulneración del principio de especialidad por falta de competencia material de la AEPD. En este sentido, al conservar los datos tan sólo en cumplimiento de la Ley 25/2007 considera que sería de aplicación el régimen sancionador específico previsto en dicha norma para los casos de que los datos personales incorporados por los operadores al libro-registro resulten incorrectos o incompletos.

Dicha norma prevé, en el apartado 5 de su disposición adicional única, en relación con la llevanza del libro-registro un régimen sancionador que persigue el mismo objetivo que el principio de exactitud previsto en el RGPD: garantizar que los datos obrantes en el libro registro sean correctos.

Entiende que en este caso se produce un concurso aparente entre ambas normas que se debe resolver a favor de la norma específica (en este caso, la Ley 25/2007) sobre la norma general (el RGPD), al exigir el principio invocado que se analice la norma especial en primer lugar y, si se cumplen los requisitos para su aplicación, esta será prioritaria frente a la general. Por ello, la competencia para resolver los procedimientos sancionadores derivados de la vulneración de la obligación de correcta llevanza del libro-registro que nos ocupa recae sobre el “Secretario de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información", según dispone el apartado 6 de la disposición adicional única de la Ley 25/2007. Aporta resolución de expediente sancionador dictada por el SETID.

Con base en el principio de especialidad, esta Agencia Española de Protección de Datos no es competente para sancionar a XFERA por la existencia de inexactitudes en los datos conservados en relación con los adquirentes de las tarjetas SIM asociadas a los números ***TELÉFONO.4 y ***TELÉFONO.2, puesto que lo es el SETID, en aplicación de la disposición adicional única de la Ley 25/2007: una norma material especial sobre el RGPD que necesariamente lo desplaza.

Responsabilidad

Por otro lado, entiende vulnerado el artículo 4 de la LOPDGDD puesto que la exoneración al responsable de velar por la exactitud de los datos facilitados directamente por el afectado buscaba precisamente evitar que la comisión de un error por parte del interesado, en el momento de facilitar sus datos personales, derivase en una sanción para el responsable del tratamiento, quien no hace más que reflejar en sus sistemas la información que le fue facilitada.

Motivación del acuerdo de inicio y proporcionalidad de la sanción propuesta

Asimismo, considera que el acuerdo de inicio carece de la debida motivación en lo que a la determinación de los hechos se refiere, pues no se concretan los criterios jurídicos en los que se fundamenta el incumplimiento de las obligaciones relativas a la debida diligencia a efectos de velar por la exactitud de los datos.

En cuanto a los criterios de graduación recogidos en el Acuerdo considera que, al tratarse de datos falsos, que no se corresponden con interesados alguno, no se puede tener en cuenta como criterio de graduación de la multa el daño sufrido por los interesados afectados. Entiende asimismo, que no existe intencionalidad o negligencia en la infracción, por su imposibilidad de comprobar la veracidad de los datos trasladados por los puntos de venta.

Asimismo, destaca los criterios de graduación que no han sido tomados en consideración: además de la falta de daño efectiva a un interesado y la ausencia de intencionalidad o negligencia por su falta de responsabilidad respecto de la conducta de los puntos de venta, su adherencia al Código de Conducta de Autocontrol para el "Tratamientos de datos en la actividad publicitaria", aprobado por la AEPD, la no obtención de beneficio derivado de la conducta presuntamente infractora y el espíritu colaborativo demostrado durante la actuación investigadora de la AEPD. En atención a estas circunstancias, solicita una disminución de la gravedad de las infracciones y de la sanción a imponer

En su escrito de alegaciones, la parte solicita la práctica de las siguientes pruebas:

1. Documental, consistente en la unión al procedimiento de los documentos aportados con este escrito;

2. Más documental, consistente en que esta digna Agencia libre atento oficio a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, sita en Madrid, Cl. Poeta Joan Maragall 41, planta 7, con correo electrónico sancionadorteleco@economia.gob.es a efectos de solicitar copia del expediente sancionador SAN00067/23, en el marco del cual se dictó la resolución aportada como documento núm. 2 de este escrito de alegaciones;

3. Testifical por escrito, consistente en que esta digna Agencia libre atento oficio a la Fullcarga Ibérica, S.L., (...), a efectos de que su representante legal conteste a las siguientes preguntas:

a. ¿Fueron comercializadas, a través de su plataforma informática, dos tarjetas prepago de la marca “Lebara”, correspondientes a las líneas móviles ***TELÉFONO.4 y ***TELÉFONO.2, los días 23 de febrero de 2022 y 3 de marzo de 2022, respectivamente?

b. En caso afirmativo, ¿pueden confirmar qué concreto establecimiento, de los adheridos a su red, comercializó las citadas tarjetas prepago?

c. ¿Facilita Fullcarga algún tipo de instrucciones, a los establecimientos adheridos a su red, sobre cómo cumplimentar los datos de los adquirentes de tarjetas prepago de telefonía móvil, a efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de identificación previstas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre?

OCTAVO: Propuesta de resolución

Con fecha 23 de enero de 2025 se formuló propuesta de resolución, proponiendo:

*“PRIMERO Que por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos se sancione a **XFERA MÓVILES, S.A.** con NIF **A82528548**, por una infracción del Artículo 5.1 d) del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD, con una multa de CIEN MIL EUROS (100.000€)*

*SEGUNDO Que por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos se ordene a **XFERA MÓVILES, S.A.** con NIF **A82528548**, que en virtud del artículo 58.2.d) del RGPD, en el plazo de 6 meses, introduzca los procedimientos y mecanismos necesarios de comprobación de la exactitud de los datos que el propio operador recolecte en el momento de tramitar las altas y portabilidades.”*

NOVENO: Alegaciones a la propuesta de resolución

Notificada la citada propuesta de resolución conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), y otorgada la ampliación del plazo para realizar alegaciones a petición del interesado, se han recibido alegaciones que, a la vez que reiteran argumentos ya expuestos previamente, aportan otros nuevos, esencialmente los siguientes:

- Tramitación del recurso de reposición: la reclamación inicialmente se archivó y solo habría sido admitida tras la resolución del recurso de reposición interpuesto por la parte reclamante. Con ello estaría ampliamente sobrepasado el plazo de 3 meses para la admisión a trámite del art 65 LOPDGDD.
- Supuesto de hecho que da lugar al expediente sancionador. La reclamación inicial se refería únicamente a la recepción de comunicaciones comerciales, siendo así que ahora la AEPD prescinde del motivo de la reclamación y sanciona por una inadecuación de los datos que conservaba XFERA
- Existencia de un informe del Ministerio del Interior que, según se afirma, desplaza la responsabilidad por la identificación de titulares de líneas prepago al titular del establecimiento o punto de venta. A estos efectos, en el informe se indicaría que dicho establecimiento sería el obligado a cumplimentar los datos; el operador de telecomunicaciones no podría comprobar su veracidad y concluiría que “La actitud del operador es satisfactoria”. Ello en el seno de un procedimiento sancionador tramitado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales (en adelante SETID) en relación con el incumplimiento de la Ley 25/2007, de 18 de octubre.
- En relación con la responsabilidad de XFERA, el art 4 LOPDGDD excluye de la responsabilidad del responsable del tratamiento en los casos en que los datos inexactos son así facilitados directamente por el interesado
- En el apartado de proporcionalidad de la sanción, consideran que no cabe considerar como agravantes la gravedad de la infracción. La AEPD indica que la gravedad viene del hecho de que el incumplimiento habría impedido determinar la autoría de las llamadas investigadas, cuando las obligaciones de XFERA no abarcan el contenido de las llamadas
- Discrepa asimismo en la consideración como agravante de la Intencionalidad o negligencia. Dado que a lo largo de sus alegaciones intenta demostrar la inexistencia de negligencia, ello iría en coherencia con su argumentación.
- Considera que la agravante de vinculación con el tratamiento habitual de datos personales, considera que la misma debe referirse al supuesto concreto de la Ley 25/2007, y no a una vinculación genérica con el desarrollo de su actividad ordinaria
- Finalmente propone la toma en consideración de atenuantes como el bloqueo de línea cuando tuvo constancia del fraude, y la ausencia tratamiento de categorías especiales;

DÉCIMO: Volumen de negocio

De acuerdo con el informe recogido de la herramienta AXESOR, la entidad XFERA MÓVILES, S.A. es una gran empresa, con un volumen de negocios de 2.098.178.000 euros en el año 2023

A la vista de todo lo actuado, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en el presente procedimiento se consideran hechos probados los siguientes,

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.

A.A.A. presentó con fecha 15 de abril de 2023 reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. contra **XFERA MÓVILES, S.A.** con NIF **A82528548** por la recepción de llamadas comerciales en las que se publicitaban los servicios de YOIGO a pesar de haberse incluido en la Lista Robinson de exclusión publicitaria.

Acompañando a su reclamación, aporta varias capturas de pantalla en las que se identifican las líneas teléfono *****TELÉFONO.2 ***TELÉFONO.3 ***TELÉFONO.4** como aquellas desde las que se realizaron las llamadas comerciales por las que reclama, así como datos sobre las fechas y horas en las que se realizaron dichas llamadas.

SEGUNDO.

XFERA es el operador que prestaba el servicio, en la fecha de realización de las llamadas, a las líneas telefónicas desde las que se realizaron las llamadas objeto de la reclamación.

TERCERO.

Consta en el expediente, aportado por la parte reclamada, un contrato de prestación de servicios de tramitación y gestión de solicitudes de recarga de saldo, fechado el 1 de septiembre de 2021 y suscrito entre XFERA MÓVILES, S.A.U., (...) y LYCAMOBILE, (denominados de forma conjunta, XFERA), y, FULLCARGA IBERICA, S.L., (...) (el proveedor).

Conforme al mismo, FULLCARGA asume la condición de encargado del tratamiento de datos personales, en la ejecución de las prestaciones encomendadas en el citado contrato.

CUARTO.

A requerimiento de la Inspección de la AEPD, XFERA facilita la siguiente información sobre los titulares de señaladas líneas telefónicas

- Datos de contacto y de identificación del titular del número de teléfono *****TELÉFONO.4** en marzo de 2022: **B.B.B. DNI ***NIF.2**
- Datos de contacto y de identificación del titular del número de teléfono *****TELÉFONO.3** en abril de 2022: **C.C.C. DNI ***NIF.2**
- Datos de contacto y de identificación del titular del número de teléfono *****TELÉFONO.2** en abril de 2022: **D.D.D. DNI ***NIF.3**

QUINTO.

El operador *****EMPRESA.2** ratifica que el número del reclamante recibió las siguientes llamadas desde los números indicados en la reclamación,

- Desde el *****TELÉFONO.4** recibió llamadas el 18/03/2022 a las 18:14 (rechazada), el 19/03/2022 a las 17:12 (4 sg) y a las 17:34, *****TELÉFONO.3** el día 11/04/2022 a las 17:51
- Desde el *****TELÉFONO.2** el día 12/04/2022 a las 13:53 (7 sg) el 13/04/2022 a las 17:32 (6 sg) el 14/04/2022 a las 17:21,

SEXTO.

No existía vínculo contractual para la realización de llamadas de contenido comercial en las fechas identificadas en la reclamación entre XFERA y los titulares de las líneas telefónicas desde las que se realizaron las llamadas objeto de reclamación.

SÉPTIMO.

Según la información aportada por la Agencia Tributaria, la búsqueda por el DNI facilitado por XFERA como correspondiente a **B.B.B.** no proporciona resultados. Asimismo, el DNI que XFERA indica como correspondiente a **D.D.D.** corresponde a otra persona.

OCTAVO.

Las tarjetas prepago correspondientes a las líneas *****TELÉFONO.4** y *****TELÉFONO.2** fueron comercializadas a través de la plataforma de la entidad Fullcarga Ibérica S.L., (...) al amparo del contrato suscrito entre ambas partes con fecha 1 de septiembre de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia

De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para resolver este procedimiento la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos.

II. Procedimiento

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: *“Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.”*

De acuerdo con el artículo 64 de la LOPDGDD, y teniendo en cuenta las características de las presuntas infracciones cometidas, se inicia un procedimiento sancionador.

El procedimiento tendrá una duración máxima de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actuaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la LOPDGDD.

III. Cuestiones previas

Según el artículo 4.1 del RGPD, ha de entenderse que son datos personales *toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;*

Asimismo, el apartado 2 de dicho precepto señala lo siguiente en cuanto al concepto de tratamiento de datos personales *cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;*

En el presente caso, de acuerdo con lo establecido en los preceptos señalados y lo reflejado en los antecedentes y en los hechos probados, consta un tratamiento de datos personales, en este caso de las líneas telefónicas desde las que se realizaron las llamadas recibidas por el reclamante y que dicho tratamiento lo realiza XFERA en su calidad de operadora de los números de teléfono desde las que se realizaron las llamadas objeto de reclamación, y en su condición de responsable del tratamiento, dado que es quien determina los fines y medios de tal actividad, en virtud del artículo 4.7 del RGPD: «Responsable del tratamiento» o «responsable»: *la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina.*

Conforme a los datos obtenidos en AXESOR, XFERA MÓVILES, S.A. es una gran empresa, con un volumen de negocios de 2.098.178.000 euros en el año 2023.

IV. Alegaciones de la parte reclamada

En respuesta a las alegaciones presentadas por la entidad reclamada, tanto al acuerdo de inicio como a la propuesta de resolución, se debe señalar lo siguiente:

.1 Caducidad de actuaciones

En relación a la alegada caducidad del recurso de reposición interpuesto el 3 de agosto de 2022, la parte reclamada considera que la resolución del recurso interpuesto por el reclamante, una transcurrido el plazo previsto en el art. 25.1 b) de la LPACAP, conlleva su caducidad y, por lo tanto, se debiera haber decretado el archivo de las actuaciones.

A este respecto, ha de señalarse que, contrariamente a lo indicado por la parte reclamante, no nos encontramos ante un supuesto de los previstos en el artículo 25 de la LPACAP - Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio-, sino en el artículo 24, cuyo apartado 1, párrafo tercero, dispone lo siguiente:

“El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.” (el subrayado es nuestro)

Cabe recordar también que la Administración está obligada a dictar resolución expresa conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1 de la misma norma y, en ese sentido, el apartado 3. b) del ya mencionado artículo 24 señala lo siguiente:

“3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen(...):

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.” (el subrayado es nuestro)

Por lo anteriormente expuesto, cabe concluir que la tramitación realizada por esta AEPD es conforme con lo dispuesto en la LPACAP y que, por lo tanto, no nos encontraríamos ante un supuesto de caducidad de las actuaciones como señala la parte reclamada.

Respecto de la alegación de la parte reclamada relativa a la caducidad de las actuaciones previas de investigación, cabe recordar que el presente procedimiento sancionador tiene su origen en la estimación del recurso de reposición interpuesto por la parte reclamante, mediante resolución de 10/04/2023, tal y como consta en el expediente. Teniendo en cuenta que la estimación de dicho recurso tuvo como consecuencia la realización de actuaciones previas de investigación y posteriormente el inicio del presente procedimiento sancionador frente al archivo de las actuaciones

inicialmente decretado, ha de considerarse que dicha fecha es la que ha de tomarse como referencia para el inicio del cómputo de los doce meses fijado en el artículo 67.2 LOPDGDD- en la redacción de dicho precepto anterior al 10/05/2023, aplicable al caso que nos ocupa-.

A esos efectos es importante señalar que el reclamante en el recurso de reposición aportó listado de llamadas, por lo que se trataba de nueva documentación que fue evaluada por la AEPD y por tal motivo el plazo de caducidad de las actuaciones previas se inicia cuando se produce la resolución estimatoria del recurso. La documentación no constaba en la reclamación original. La resolución de recurso de reposición tiene fecha de 10/04/2023.

En complemento de este argumento, ha de recordarse, asimismo, que dicho precepto se incardina en el Título VIII de la LOPDGDD, procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos, y, en ese sentido, y, como decimos, frente al archivo inicialmente acordado, el procedimiento por una posible vulneración de la normativa de protección de datos personales sólo fue iniciado tras la estimación del recurso de reposición presentado por la parte reclamante.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que el acuerdo de inicio de expediente sancionador según consta en el expediente, fue firmado con fecha 04/04/2024, ha de entenderse que el plazo previsto en el art. 67.2 LOPDGDD fue debidamente respetado.

En relación con la alegación referida al transcurso de un plazo superior a tres meses desde la recepción de la reclamación hasta su admisión a trámite, es preciso recordar que la superación del plazo viene producida por los hechos señalados por la propia parte reclamada. En una primera instancia la reclamación fue archivada, y solo fue admitida a trámite tras la resolución del recurso de reposición interpuesto por la parte reclamante. Con ello, dicha admisión a trámite no fue como consecuencia de la tramitación ordinaria de la reclamación, sino como tras la actividad revisora llevada a cabo en la tramitación y resolución del recurso de reposición. En todo caso, la admisión a trámite no prejuzga ni mucho menos la consideración de un incumplimiento que dé lugar a la tramitación de un procedimiento sancionador, sino que este solo ha sido iniciado tras la realización de las actuaciones previas de investigación previstas en el artículo 67 de la LOPDGDD y detalladas en los antecedentes de esta resolución.

.2 Supuesto de hecho del procedimiento

Dentro de las alegaciones calificadas como jurídico-materiales, la parte reclamada indica que por parte de la AEPD se habría modificado el supuesto de hecho objeto del procedimiento. Si bien la reclamación se presentó referida a la recepción de llamadas comerciales no solicitadas o consentidas, el objeto del procedimiento sancionador sería una presunta falta de exactitud de los datos objeto de conservación por XFERA bajo las obligaciones de la Ley 25/2007, de 18 de octubre.

En relación con esta alegación, el procedimiento seguido ha sido el siguiente:

- Efectivamente, la reclamación tiene por objeto la denuncia de la recepción de llamadas comerciales por la parte reclamante

- Como se establece en los hechos probados, XFERA es el operador de telecomunicaciones al cual pertenecen las líneas desde las cuales habrían sido efectuadas las llamadas de carácter comercial objeto de la reclamación
- Durante la investigación, se ha requerido por parte de la Inspección de esta AEPD a XFERA la identificación de los titulares de las líneas telefónicas. Ello con objeto de poder determinar posibles responsabilidades en las llamadas denunciadas
- XFERA suministró a esta Agencia los datos de identidad que constaban en sus sistemas.
- Como se indica en los hechos probados de esta resolución, tras una consulta a la AEAT, se concluye que los datos eran claramente inexactos. En relación con una de las líneas telefónicas, el DNI facilitado por XFERA como correspondiente a la persona física titular de una de las líneas “no proporciona resultados”. Asimismo, el DNI que XFERA indica como correspondiente a otra de ellas corresponde a otra persona.

Existían por lo tanto, claros indicios de que XFERA habría incumplido el principio de exactitud de datos personales (art 5.1.d RGPD) toda vez que se habrían atribuido a la línea telefónica en cuestión datos personales que no se correspondían con su titularidad. Esta presunta infracción tendría una competencia sancionadora que corresponde a esta AEPD, al constituir un incumplimiento del RGPD.

A este respecto la Sentencia del Tribunal Supremo de 11/11/2024 indica lo siguiente:

“Con esas precisiones sobre la manera en que el auto de admisión del recurso formula la cuestión de interés casacional, la cuestión a dilucidar consiste en realidad en si, en la incoación, tramitación y resolución de un procedimiento sancionador, la Agencia Española de Protección de Datos queda vinculada, y en qué forma y grado, por el contenido de la reclamación que ante ella se haya presentado.

Y, formulada la cuestión en esos términos, para responderla debemos declarar lo que sigue:

La Agencia Española de Protección de Datos, en la incoación, tramitación y resolución de un procedimiento sancionador, puede abordar cuestiones fácticas y jurídicas conexas o relacionadas con los hechos y argumentos recogidos en la reclamación que da origen al procedimiento. Y, más específicamente, en el curso de un procedimiento sancionador iniciado a raíz de una o varias reclamaciones en materia de protección de datos personales, cuando se aprecie que las infracciones singulares denunciadas tienen sus origen común en un documento o instrumento de alcance general que define la política de la entidad en materia de protección de datos, la AEPD puede, y aún debe, hacer objeto del procedimiento sancionador a ese mismo documento que alberga la política de privacidad de la entidad responsable, a fin de examinarlo, detectar sus posibles

carencias o deficiencias, y adoptar, en consecuencia, las medidas que resulten necesarias en el seno del propio procedimiento sancionador; en el bien entendido de que de todo ello habrá de darse conocimiento al sujeto del expediente, de manera que durante la tramitación del procedimiento pueda este tener ocasión de formular alegaciones y, en su caso, proponer pruebas, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.”

Como es lógico, reconoce el Tribunal Supremo la posibilidad de sancionar infracciones que surjan de las cuestiones objeto del procedimiento, sin que esta Agencia tenga que estar constreñida por la narración concreta de los hechos detallada por la parte reclamante. Lo contrario implicaría una dejación de funciones ante la constatación de evidencias que ponen de manifiesto la posible comisión de una infracción.

.1 Competencia de la AEPD

Aparte, las alegaciones materiales por la parte reclamada versan, en esencia, sobre la calificación de la conducta antijurídica presuntamente cometida, la ausencia de competencia de la AEPD y la responsabilidad de la parte reclamada en su comisión en atención a los hechos acaecidos.

En relación con la posible falta de competencia de esta Agencia, hace notar la parte reclamada que la competencia sancionadora por la falta de llevanza del libro – registro de líneas prepago, conforme a la Ley 25/2007, de 18 de octubre, correspondería a la SETID. A este respecto, cabe comenzar señalando que, según el artículo 8-Protección y seguridad de los datos- de dicha Ley:

“2. Las obligaciones relativas a las medidas para garantizar la calidad de los datos y la confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los mismos serán las establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo. (...)

4. La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad pública responsable de velar por el cumplimiento de las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y de la normativa de desarrollo aplicables a los datos contemplados en la presente Ley.”

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que la calidad de los datos está directamente relacionada con que éstos sean exactos, en el sentido de que sean reflejo de una situación real. Dicho de otro modo, no puede predicarse de unos datos inexactos que cumplan con el requisito de calidad.

Asimismo, resulta claro del precepto transcrito que dicha calidad en la información ha de garantizarse de acuerdo a lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales. Normativa que ha de entenderse referida al RGPD y a la LOPDGD. En consecuencia, por lo señalado, puede concluirse que dicha obligación- garantizar la calidad de los datos tratados en cumplimiento de la Ley 25/2007- se corresponde con el principio de exactitud de los datos previsto en el artículo 5.1 d) del RGPD- y que su cumplimiento ha de garantizarse de acuerdo a lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos personales actualmente en vigor: el RGPD y la LOPDGD.

Dicho lo anterior, y toda vez que la AEPD es la entidad competente para velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales- como, además del RGPD y la LOPDGDD, el propio artículo 8.4 de la Ley 25/2007 señala expresamente- ha de rechazarse la alegación relativa a la incompetencia material para resolver la comisión presuntamente cometida por la parte reclamada objeto del presente procedimiento sancionador. La obligación deriva de la Ley 25/2007, pero con obligación o sin ella, los datos personales que trata un responsable tienen cumplir el principio de exactitud del RGPD.

En sus alegaciones a la propuesta de resolución, la parte reclamada incide en la posible existencia de un “concurso de leyes”, de modo que, en caso de considerarse que tanto la AEPD como la SETID tuvieran competencia sancionadora por una misma infracción, el concurso debería resolverse en favor de esta última, por el principio de especialidad.

A este respecto, no es preciso acudir al conflicto de leyes para resolver la cuestión. Debe analizarse la razón para sancionar que tendría cada uno de estos organismos. La Ley 25/2007, de 18 de octubre, otorga competencias a la SETID para sancionar infracciones como (disposición adicional única apartado 5): *“El incumplimiento de la llevanza del libro-registro referido; la llevanza reiterada o sistemáticamente incompleta de dicho libro-registro; el incumplimiento deliberado de la cesión y entrega de los datos a las personas y en los casos previstos en esta disposición; la llevanza incompleta del libro-registro o el incumplimiento de la cesión y entrega de los datos a las personas y en los casos previstos en esta disposición”*

Dicha Ley tiene por objeto garantizar que los operadores de telecomunicaciones conserven los datos relativos a los clientes y abonados de los operadores, por si fuera preciso que los pongan a disposición de las Fuerzas y cuerpos de seguridad. El bien jurídico protegido es la seguridad pública y se encomienda a la SETID velar por el mismo, a través de su competencia sancionador. Para ello, aplica el régimen de infracciones y sanciones previsto en la propia Ley 25/2007.

Por el contrario, en este expediente la AEPD está supervisando el cumplimiento de los principios básicos del derecho fundamental a la protección de datos, que corresponde a los titulares de los mismos. Y lo cierto es que, como se motiva en esta resolución, no se ha garantizado el principio de exactitud al vincularse nombres, direcciones, números de teléfonos y documentos identificativos que eran inexactos. Esta resolución sanciona por el incumplimiento de un principio básico de la protección de datos personales, establecido en el art 5.1.d) del RGPD y no aplica el régimen sancionador de la Ley 25/2007, sino el del propio RGPD complementado con las disposiciones de la LOPDGDD.

Cuestión distinta es que para determinar el régimen sustantivo que se aplica al sector de la conservación de datos personales en las comunicaciones electrónicas, se acuda a una norma sectorial, en este caso la Ley 25/2007, al igual que esta Agencia lo hace otros múltiples sectores para determinar si se produce alguna vulneración de la normativa de protección de datos en los mismos.

Por lo demás, no consta ni ha sido alegado por el interesado, que la SETID haya abierto algún expediente sancionador por estos mismos hechos, de modo que pudiera

enjuiciarse un posible “bis in ídem”, (en el que, como hemos dicho, se estimaría que cada Administración actúa en protección de un bien jurídico diferente)

3. Modelo de comercialización de tarjetas prepago. Encargado del tratamiento

Señala la reclamada su ausencia de responsabilidad respecto del incumplimiento imputado en atención a las condiciones en las que se produce la venta de las tarjetas telefónicas por los puntos de venta habilitados para ello. Entiende que es la imposibilidad de ejercer un control sobre la práctica llevada a cabo por estos puntos de venta y, sobre todo, la imposibilidad de evitar casos de fraude en la identificación de los adquirentes- y, por ende, en los datos que son recabados para dar cumplimiento a la Ley 25/2007 y cumplir con los fines previstos en la misma- la circunstancia que implica que XFERA no pueda ser responsable de la conducta objeto de este procedimiento.

Ciertamente, el principio de responsabilidad previsto en el artículo 28 de la LRJSP, dispone que: *“Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.”* No obstante, el modo de atribución de responsabilidad a las personas jurídicas no se corresponde con las formas de culpabilidad dolosas o imprudentes que son imputables a la conducta humana. De modo que, en el caso de infracciones cometidas por personas jurídicas, aunque haya de concurrir el elemento de la culpabilidad, éste se aplica necesariamente de forma distinta a como se hace respecto de las personas físicas. Según la STC 246/1991, de 19 de diciembre Rec 1274/1988 “ (...) esta construcción distinta de la imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona jurídica nace de la propia naturaleza de ficción jurídica a la que responden estos sujetos. Falta en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad de infringir las normas a las que están sometidos.

Capacidad de infracción y, por ende, reprochabilidad directa que deriva del bien jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad de que dicha protección sea realmente eficaz y por el riesgo que, en consecuencia, debe asumir la persona jurídica que está sujeta al cumplimiento de dicha norma” (en este sentido STS de 24 de noviembre de 2011, Rec 258/2009).

A lo expuesto debe añadirse, siguiendo la sentencia de 23 de enero de 1998, parcialmente trascrita en las SSTs de 9 de octubre de 2009, Rec 5285/2005, y de 23 de octubre de 2010, Rec 1067/2006, que *“aunque la culpabilidad de la conducta debe también ser objeto de prueba, debe considerarse en orden a la asunción de la correspondiente carga, que ordinariamente los elementos volitivos y cognoscitivos necesarios para apreciar aquélla forman parte de la conducta típica probada, y que su exclusión requiere que se acredite la ausencia de tales elementos, o en su vertiente normativa, que se ha empleado la diligencia que era exigible por quien aduce su inexistencia; no basta, en suma, para la exculpación frente a un comportamiento típicamente antijurídico la invocación de la ausencia de culpa”*.

Finalmente, cabe recordar que la SAN de 22 de junio de 2021, Rec. 1210/2018, al valorar el elemento subjetivo o culpabilístico, que la culpabilidad de la parte actora no puede considerarse excluida ni atenuada por el hecho de que haya mediado la posible actuación fraudulenta de un tercero, pues la responsabilidad de la parte actora no deriva de la actuación de éste, sino de la suya propia.

La figura del encargado del tratamiento

La figura del encargado del tratamiento obedece a la necesidad de dar respuesta a fenómenos como la externalización de servicios por parte de las empresas y otras entidades, de manera que en aquellos supuestos en que el responsable del tratamiento encomiende a un tercero la prestación de un servicio que requiera que el encargado trate datos personales por su cuenta, el tratamiento o las operaciones del tratamiento se llevan a cabo por el encargado, en nombre y por cuenta del responsable, como si fuera este último quien lo lleva a cabo.

Por lo tanto, la existencia de un encargado del tratamiento depende de una decisión adoptada por el responsable del tratamiento, que podrá decidir realizar por sí mismo determinadas operaciones de tratamiento o contratar la totalidad o parte del tratamiento con un encargado.

Es decir, que el encargado, para serlo, no ostenta ningún interés propio respecto del resultado del tratamiento objeto de encargo, sin perjuicio de la compensación económica que recibe por el servicio prestado y que es lo que acontece en el presente caso. Los encargados no tienen ningún interés propio, actúan por cuenta y en nombre del responsable, cumpliendo sus órdenes y para las finalidades de éste, y esto es lo que determina que sean encargados desde el principio.

Ello determina que responde el responsable del tratamiento de actuaciones contrarias al RGPD llevadas a cabo por sus encargados del tratamiento, a salvo que estos últimos hubieran actuado como verdaderos responsables del tratamiento, decidiendo sobre los fines y medios del tratamiento, cuestión que no ha acontecido en el presente supuesto.

Así, la STJUE de 5 de diciembre de 2023 dictada en el asunto C-683/21, en cuanto a la cuestión de si puede imponerse una multa administrativa con arreglo al artículo 83 del RGPD a un responsable del tratamiento en relación con las operaciones de tratamiento efectuadas por un encargado, determina que,

“83 Por lo que respecta, en segundo lugar, a la cuestión de si puede imponerse una multa administrativa con arreglo al artículo 83 del RGPD a un responsable del tratamiento en relación con las operaciones de tratamiento efectuadas por un encargado, es preciso recordar que, según la definición que figura en el artículo 4, punto 8, del RGPD, se entiende por encargado del tratamiento «la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento».

84 Dado que, como se ha indicado en el apartado 36 de la presente sentencia, un responsable del tratamiento es responsable no solo por todo tratamiento de datos personales que efectúe él mismo, sino también por los

tratamientos realizados por su cuenta, puede imponerse a ese responsable una multa administrativa con arreglo al artículo 83 del RGPD en una situación en la que los datos personales son objeto de un tratamiento ilícito y en la que no es él, sino un encargado al que ha recurrido, quien ha efectuado el tratamiento por cuenta suya.

85 No obstante, la responsabilidad del responsable del tratamiento por el comportamiento de un encargado no puede extenderse a las situaciones en las que el encargado haya tratado datos personales para fines que le sean propios o en las que haya tratado dichos datos de manera incompatible con el marco o las modalidades del tratamiento tal como hayan sido determinados por el responsable del tratamiento o de manera que no pueda considerarse razonablemente que dicho responsable hubiera dado su consentimiento. En efecto, de conformidad con el artículo 28, apartado 10, del RGPD, el encargado del tratamiento debe, en ese supuesto, ser considerado responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento”. (el subrayado es nuestro)

A lo anterior, hemos de adicionar la Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de febrero de 2024, rec. 0002250/2021, respecto de *****EMPRESA.4**, en la que se determina que,

“Pues bien, la sociedad recurrente es la responsable del tratamiento, pues determina la finalidad y medios de los tratamientos realizados con las finalidades señaladas en su Política de Privacidad: “En *****EMPRESA.5** tratamos los datos del cliente o usuario para la prestación del servicio, así como para otras finalidades que el mismo permita o autorice en los términos informados en la presente Política de Privacidad o en las Condiciones específicas de cada Producto o Servicio *****EMPRESA.5** contratado”.

Mientras que las compañías *****EMPRESA.6**, *****EMPRESA.7** y *****EMPRESA.8**, tienen la consideración de encargados del tratamiento.

Lo expuesto se deriva de los contratos suscritos por la parte actora con las citadas compañías.

....

Pues bien, no ha que quedado acreditado que las citadas empresas, como encargadas del tratamiento de la parte actora, hayan determinado fines y medios del tratamiento, ni hayan utilizado los datos de los clientes de aquella para sus propias finalidades, ni han interactuado frente a los interesados ajenos a la estructura y nombre comercial de la sociedad recurrente, sino que han actuado bajo el nombre de la parte actora para el cumplimiento de los fines de estos, utilizando los sistemas de ésta para realizar las operaciones con los clientes.

Por lo que, no cabe invocar el art. 28.10 del RGPD para una presunta atribución de responsabilidad a los encargados que, además, implique la exoneración del responsable del tratamiento, es decir, de la sociedad aquí recurrente. Por otro lado, conforme a los reseñados contratos, se incluye una

cláusula que repercute en ellos las posibles sanciones que la sociedad demandante pudiera sufrir por el incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos". (el subrayado es nuestro)

Por otro lado, las Directrices 7/2020 del CEPD sobre los conceptos de «responsable del tratamiento» y «encargado del tratamiento» en el RGPD, versión 2.0 Adoptada el 7 de julio de 2021, determinan que,

“30 Siguiendo la línea del enfoque basado en los hechos, la palabra «determine» significa que el ente que realmente ejerce una influencia decisiva sobre los fines y medios del tratamiento es el responsable. Por lo general, el contrato de tratamiento establece quién es la parte determinante (el responsable del tratamiento) y quién, la parte que sigue las instrucciones (el encargado del tratamiento). Incluso cuando el encargado del tratamiento ofrezca un servicio que se defina previamente de un modo concreto, deberá presentar al responsable del tratamiento una descripción detallada del servicio, y este deberá adoptar la decisión final sobre la aprobación del modo en que se efectuará el tratamiento y solicitar los cambios que considere necesarios. Además, el encargado del tratamiento no puede modificar, en un momento posterior, los elementos esenciales del tratamiento sin la aprobación del responsable.

...

39. La cuestión es dónde se debe trazar la línea entre las decisiones reservadas al responsable del tratamiento y aquellas que pueden dejarse a la discreción del encargado. Es evidente que las decisiones sobre el fin del tratamiento siempre deben corresponder al responsable.

40. Por lo que respecta a la determinación de los medios, cabe distinguir entre los medios esenciales y los no esenciales. Los medios esenciales se reservan tradicionalmente y de forma inherente al responsable del tratamiento. Estos deben ser determinados obligatoriamente por el responsable del tratamiento, aunque la determinación de los medios no esenciales también puede dejarse en manos de él. Los medios esenciales son medios estrechamente ligados al fin y el alcance del tratamiento, como el tipo de datos personales tratados («¿qué datos se tratarán?»), la duración del tratamiento («¿cuánto tiempo se tratarán?»), las categorías de destinatarios («¿quién tendrá acceso a los datos?») y las categorías de interesados («¿a quién pertenecen los datos personales tratados?»). Además de estar relacionados con el fin del tratamiento, los medios esenciales se encuentran estrechamente vinculados a la cuestión de si el tratamiento es lícito, necesario y proporcionado. Los medios no esenciales están relacionados con aspectos más prácticos del tratamiento en sí, como la elección de un tipo particular de hardware o software o la decisión sobre los pormenores de las medidas de seguridad, que pueden dejarse en manos del encargado del tratamiento.

41. Pese a que las decisiones sobre los medios no esenciales pueden dejarse en manos del encargado del tratamiento, el responsable aún deberá estipular ciertos elementos en el contrato con el encargado: por ejemplo, en relación con el requisito de seguridad, podrá ordenarse la adopción de todas las medidas

exigidas en virtud del artículo 32 del RGPD. El contrato también debe establecer que el encargado del tratamiento ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de, por ejemplo, lo dispuesto en el artículo 32. En cualquier caso, el responsable del tratamiento sigue siendo responsable de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento (artículo 24). Para ello, el responsable debe tener en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, además de los riesgos para los derechos y las libertades de las personas físicas. Por este motivo, el responsable del tratamiento debe contar con una información completa sobre los medios utilizados, ya que, así, podrá adoptar una decisión informada al respecto. Para que el responsable pueda demostrar la legalidad del tratamiento, se aconseja documentar, en el contrato u otro instrumento jurídicamente vinculante entre el responsable y el encargado, al menos las medidas técnicas y organizativas necesarias.

...

74. El RGPD establece obligaciones concretas que vinculan directamente a los encargados del tratamiento, tal como se especifica en la sección 1 del apartado II de las presentes directrices. Es posible exigir responsabilidad o sancionar a un encargado cuando no cumpla con dichas obligaciones o actúe al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable.

...

80 En segundo lugar, el tratamiento debe llevarse a cabo por cuenta de un responsable del tratamiento, pero no bajo su autoridad ni control directos. Actuar «por cuenta de» alguien significa servir los intereses de otro y remite al concepto jurídico de «delegación». En el caso de la normativa de protección de datos, el cometido del encargado del tratamiento es aplicar las instrucciones dadas por el responsable del tratamiento, cuando menos en lo relativo a los fines del tratamiento y a los elementos esenciales de los medios. La legitimidad del tratamiento en virtud del artículo 6 y, si procede, del artículo 9 del Reglamento deriva de la actividad del responsable, y el encargado únicamente debe tratar los datos siguiendo las instrucciones dadas por este. Aun así, tal como se ha indicado previamente, las instrucciones del responsable del tratamiento pueden dejar cierto margen de discrecionalidad sobre el modo de servir mejor a los intereses de este, de modo que permitan al encargado elegir los medios técnicos y organizativos más adecuados.

81. Actuar «por cuenta de» alguien también significa que el encargado no puede llevar a cabo el tratamiento para sus propios fines. Tal como se estipula en el artículo 28, apartado 10, el encargado del tratamiento infringirá el RGPD cuando no se ciña a las instrucciones del responsable y comience a determinar sus propios fines y medios del tratamiento. En estos casos, el encargado del tratamiento se considerará responsable en relación con dicho tratamiento y podrá ser sancionado por no haberse adherido a las instrucciones del responsable". (el subrayado es nuestro)

Partiendo de lo anterior, consta en el expediente, aportado por la parte reclamada, contrato de prestación de servicios de tramitación y gestión de solicitudes de recarga

de saldo, fechado el 1 de septiembre de 2021 y suscrito entre XFERA MÓVILES, S.A.U., con CIF A-82528548 y LYCAMOBILE, (denominados de forma conjunta, XFERA), y, FULLCARGA IBERICA, S.L., con CIF B-31867534 (el proveedor).

En dicho contrato se especifica que XFERA es una entidad habilitada para la prestación de servicios de comunicaciones móviles personales, operando en la actualidad bajo las marcas YOIGO, MASMOVIL, LLAMAYA, LEBARA, HITS MOBILE, LYCAMOBILE y otras marcas y sus signos distintivos. (el subrayado es nuestro).

El indicado contrato de septiembre de 2021 tiene por objeto sustituir el previamente firmado- en octubre de 2019) por ambas partes con la finalidad de establecer los términos y condiciones que rigen la prestación por EL PROVEEDOR de:

- a) Los servicios de tramitación y gestión de las solicitudes de recarga de saldo cursadas por los clientes del servicio prepago y
- b) La comercialización de tarjetas SIM en los puntos de venta asociados a la red de distribución de EL PROVEEDOR.

La cláusula tercera del indicado contrato de septiembre de 2021 indica lo siguiente:

XFERA suministrará a EL PROVEEDOR para su comercialización en su red de distribución las tarjetas SIM de las marcas LLAMAYA, LEBARA y LYCAMOBILE EL PROVEEDOR adquirirá dichas tarjetas SIM en propiedad de acuerdo con las condiciones económicas de adquisición y pago establecidas por XFERA(...)

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir y hacer cumplir en su red de distribución el código de conducta y las condiciones de comercialización de las marcas de comerciales de XFERA, tal y como se detalla en el Anexo 2 y a obligarse a que todos los distribuidores de dicha red firmen en sus respectivos contratos o acuerdos comerciales el respeto y el seguimiento de dicho código de conducta y condiciones de comercialización. (...)

SEXTA.- COMERCIALIZACION DE LAS RECARGAS POR EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR sólo tendrá derecho a comercializar y vender los productos directamente a consumidores finales, a través de sus propios canales de distribución.

No le estará permitido utilizar los canales de venta y puntos de venta de una red de terceros sin el previo consentimiento por escrito de XFERA, siendo esto considerado incumplimiento contractual muy grave.

Las autorizaciones de venta a subdistribuidores serán otorgadas por XFERA, por escrito, y limitadas al plazo de vigencia del contrato. En ningún caso se prorrogarán automáticamente con la prórroga del contrato, sino que deberán ser objeto de prórroga explícita por escrito con cada renovación contractual.

EL PROVEEDOR deberá solicitar autorización para la realización de recargas a través de nuevas tiendas web a clientes finales, tanto de forma directa como a través de clientes de EL PROVEEDOR, no pudiéndose realizar este tipo de recargas sin disponer de la autorización previa, expresa y escrita de XFERA.

El incumplimiento de esta previsión por parte de EL PROVEEDOR se considerará un incumplimiento contractual grave con entidad suficiente para desplegar los efectos establecidos en la cláusula undécima del presente contrato.

Para garantizar que la venta real a los comercios minoristas la realiza EL PROVEEDOR, y no un subdistribuidor o revendedor, la política comercial de XFERA para todas sus entidades recargadoras, se exige que el servicio al punto de venta sea prestado inequívocamente por EL PROVEEDOR mediante el cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes Requisitos (...)

UNDÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (...)

Con el fin de poder prestar a XFERA los Servicios, el PROVEEDOR deba tratar datos de carácter personal cuyo responsable sea XFERA, el PROVEEDOR actuará en nombre y por cuenta de éste, asumiendo la posición de encargado del tratamiento, todo ello en cumplimiento del artículo 28 del Reglamento (UE) General de Protección de Datos ("RGPD") y demás normativa que resulte aplicable, así como de conformidad con lo dispuesto en el Anexo de Encargo de Tratamiento que se adjunta al presente Contrato, como Anexo 4 como parte inseparable del mismo.

DÉCIMOSEXTA.- CÓDIGO ÉTICO DE PROVEEDOR

Con el fin de cumplir con las normas nacionales, europeas e internacionales, así como los convenios internacionales y demás usos de comercio y con el fin de garantizar una responsabilidad corporativa adecuada y desarrollo sostenible, XFERA requiere a sus proveedores el cumplimiento de una política de grupo de estándares éticos y de conductas responsables, así como unos requisitos de sostenibilidad relevantes. (...)

El PROVEEDOR deberá proporcionar de forma regular a XFERA la información y los datos relacionados con el cumplimiento del Código por parte del PROVEEDOR y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento del mismo. XFERA tendrá también el derecho a realizar auditorías de acuerdo con esta sección para verificar el cumplimiento del Código por parte del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR informará sin demora a XFERA de cualquier sospecha de incumplimiento del Código o de cualquiera de sus anexos.

El PROVEEDOR deberá reflejar el contenido del Código en sus acuerdos con sus subcontratistas.

En el caso de que el PROVEEDOR detecte un incumplimiento del Código este deberá, previa notificación por escrito a XFERA remediar dicho incumplimiento tan pronto resulta posible. Si dicho incumplimiento sustancial no fuera subsanado dentro de los treinta (30) días naturales después de dicha notificación, se considerará que el PROVEEDOR ha incumplido el Contrato y XFERA tendrá derecho a rescindirlo de conformidad con lo establecido en el mismo.

Revisado el contrato de encargo de tratamiento (anexo 4), en el mismo se señala lo siguiente:

i. El objeto y naturaleza del encargo del tratamiento viene definido en la cláusula 1 del Contrato Principal, en el que se incluyen diversos servicios prestados por el PROVEEDOR.

ii. El tratamiento a realizar por el Encargado tiene como finalidad la prestación de los servicios de tramitación y gestión de las solicitudes de recarga de saldo cursadas por los Clientes del servicio de comunicaciones electrónicas móviles prepago de XFERA; la comercialización de tarjetas SIM (incluyendo la identificación e inclusión de datos en el Libro Registro); y el desarrollo, mantenimientos y gestión del Portal único de Ventas para la red de distribución de XFERA.

iii. Los datos personales tratados en los términos del presente serán datos identificativos, de contacto y de pago de clientes de XFERA que realicen recargas, así como los datos de nacionalidad y número de documento acreditativo de la identidad que se proporcionarán en el momento de adquisición de la tarjeta SIM. Sobre estos datos se desarrollarán las siguientes actividades de tratamiento: recogida, registro, estructuración, extracción, consulta, comunicación por transmisión y conservación.

En su cláusula 2.1 se señala lo siguiente:

El ENCARGADO DE TRATAMIENTO, llevará a cabo el tratamiento de datos personales derivado de la prestación del servicio contratado, de conformidad con las siguientes obligaciones:

- *Limitarse a realizar las actuaciones que resulten necesarias para prestar al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO el servicio contratado, de conformidad con lo establecido en el Contrato Principal de servicios*

En concreto, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a realizar el tratamiento de los datos personales ajustándose a las instrucciones que, en cada momento, le indique el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, así como a lo dispuesto en la normativa que le resulte aplicable en materia de protección de datos personales, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o a una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en cuyo caso, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO informará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de esa exigencia legal con carácter previo al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

En la cláusula 3- Obligaciones del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO- se indica lo siguiente:

*Corresponden al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO las siguientes obligaciones:
(...)*

- *Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.*

De todo cuanto antecede cabe concluir que XFERA tenía- y debió ejercer- capacidad de supervisión respecto de la actuación de FULLCARGA y, por ende, de los puntos autorizados por ésta. A lo que debe añadirse la condición de encargado del tratamiento FULLCARGA respecto de los datos personales tratados por esta entidad en atención a los fines y medios previamente identificados por el responsable, XFERA

Ello implica, a sensu contrario y conforme determina la normativa de protección de datos, las sentencias precitadas y las Directrices 7/2020, que el responsable del tratamiento responde de las actuaciones llevadas a cabo por su encargado de tratamiento a salvo que este determine fines y medios, resultando que esta última cuestión no ha quedado acreditada en el procedimiento tramitado.

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto, XFERA MÓVILES es la responsable del tratamiento que se realiza, es quien ha decidido encomendar a un encargado del tratamiento que lo realice en su nombre y por su cuenta, es la entidad que tiene la verdadera capacidad para ejercer el control sobre el tratamiento de datos personales, quien determina qué datos personales serán tratados en su nombre y por su cuenta, el por qué y el cómo deberán tratarse estos, pues define la finalidad del tratamiento de datos personales que su actividad comprende y elige los medios que considera oportuno.

Y conforme a todo lo antedicho y para el caso concreto XFERA MÓVILES es responsable de la infracción del RGPD aun cuando la contratación de una línea móvil prepago concreta se haya producido materialmente a través de su encargado del tratamiento.

Esto se relaciona directamente con el principio de responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento previsto en el artículo 5.2 del RGPD que establece que «el responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo (“responsabilidad proactiva”)». Esto significa que el responsable deberá garantizar la aplicación efectiva de los principios del tratamiento tanto en el momento de determinar los medios del tratamiento como durante el tratamiento en sí, bien lleve a cabo el tratamiento de datos personales directamente o encargue a un encargado del tratamiento que lo realice por su cuenta (a efectos de la normativa de protección de datos es lo mismo), a través de la articulación de una serie de medidas técnicas y organizativa de todo tipo, las cuales deberán ser objeto de revisión y actualización periódica. Ello implica que el citado responsable es el que asume su propia responsabilidad dirigiendo, revisando y coordinando el tratamiento, incluyendo la del personal y la del encargado del tratamiento que le presta servicios.

El Dictamen 3/2010, del Grupo de Trabajo del artículo 29 (GT29) -WP 173- emitido durante la vigencia de la derogada Directiva 95/46/CEE, cuyas previsiones son aplicables en la actualidad, afirma que la “esencia” de la responsabilidad proactiva es la obligación del responsable del tratamiento de aplicar medidas que, en circunstancias normales, garanticen que en el contexto de las operaciones de tratamiento se cumplen las normas en materia de protección de datos y en tener disponibles documentos que demuestren a los interesados y a las Autoridades de

control qué medidas se han adoptado para alcanzar el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos.

Se tiene en cuenta a estos efectos lo señalado en el considerando 74 del RGPD,

“Debe quedar establecida la responsabilidad del responsable del tratamiento por cualquier tratamiento de datos personales realizado por él mismo o por su cuenta. En particular, el responsable debe estar obligado a aplicar medidas oportunas y eficaces y ha de poder demostrar la conformidad de las actividades de tratamiento con el presente Reglamento, incluida la eficacia de las medidas. Dichas medidas deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.” (el subrayado es nuestro)

Completando lo anterior y en desarrollo del artículo 5.2 del RGPD se ha de citar el artículo 24 y 25 del mismo texto legal, indicando este último respecto a la “Protección de datos desde el diseño y por defecto” que el derecho fundamental a la protección de los datos personales es mucho más que mera tecnología, pues su enfoque es en los riesgos en los derechos y libertades de los interesados derivados del tratamiento de los datos personales,

“1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del presente Reglamento y proteger los derechos de los interesados.

2. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento...”

XFERA MÓVILES parece sostener que la responsabilidad la tiene el encargado del tratamiento con el que suscribió un contrato y en cuya virtud se obligaba a la implementación de las medidas organizativas de seguridad adecuadas al riesgo. Como se ha motivado por esta Agencia en párrafos precedentes es XFERA quien ha determinado fines y medios del tratamiento, que es responsable del tratamiento, que es responsable de la exactitud de los datos conservados por las actuaciones de tratamiento efectuadas por su encargado de tratamiento por cuenta de aquella y que está sujeta a las obligaciones del RGPD, especialmente en cuanto a la responsabilidad proactiva.

Ello es responsabilidad de XFERA por cuanto, es la responsable del tratamiento y es quien tiene la obligación de integrar y desplegar la protección de datos dentro de todo lo que constituya su organización, en todos sus ámbitos de actuación, ya afecten a sus

empleados o a sus encargados del tratamiento. Se debe de tener muy presente que en última instancia la finalidad determinante es la de garantizar la protección del interesado, pues el foco está los riesgos en los derechos y libertades de los interesados derivados del tratamiento de datos personales que realiza el responsable del tratamiento.

Por consiguiente, el responsable del tratamiento debe llevar a cabo un análisis de los riesgos de los derechos y libertades de las personas físicas en los tratamientos de datos, implantando las medidas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del RGPD, debiendo poder demostrar que el tratamiento es conforme con lo previsto en la citada norma. Y a la luz del principio de responsabilidad proactiva (art 5.2 RGPD), el responsable del tratamiento debe poder demostrar que ha tomado en cuenta todos los elementos previstos en el RGPD.

Y, dentro de las actuaciones que lleve a cabo para garantizar que su encargado del tratamiento respeta los principios del RGPD, no se encuentran las meramente preventivas, como la firma del contrato de encargo, establecimiento de obligaciones en el mismo, e incluso dictado de instrucciones, sino que puede y debe complementarse con medidas reactivas o de control a posteriori, como sería la realización de controles o auditorías tendentes a comprobar la posible existencia de errores o inexactitudes. En este caso, referidos a los datos de identificación de titulares de líneas prepago, de las que, como se ha dicho XFERA es responsable del tratamiento.

Todo ello no hace sino reflejar una falta de diligencia por parte de la entidad responsable a la hora de garantizar la exactitud de los datos objeto de tratamiento. En este sentido, no debe olvidarse que en la base de datos afectada se encuentran almacenados datos personales de miles de clientes, lo cual supone un tratamiento a gran escala. Y la ley establece que los datos tienen que permanecer a disposición de las Fuerzas y cuerpos de seguridad para la realización de investigaciones penales, con lo que posibles inexactitudes o errores en los datos pueden desembocar a su vez en el fracaso o ralentización de dichas investigaciones.

Tal y como se ha venido demostrando y argumentando a lo largo del presente procedimiento sancionador, se considera que XFERA no había implantadas unas medidas y controles adecuados para garantizar la corrección de los datos personales de los clientes, lo que determinó en este supuesto que la investigación de la AEPD no pudiera prosperar por no corresponderse la identidad proporcionada con los verdaderos titulares de las líneas prepago

Es mucho más, es una falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas por el RGPD. Por tanto, se insiste, en que el responsable del tratamiento debe establecer, en su relación con el encargado del tratamiento, modalidades claras para dicha asistencia y dar instrucciones precisas al encargado del tratamiento sobre cómo cumplirlas de forma adecuada y documentarlo previamente a través de un contrato o bien en otro acuerdo (vinculante) y también posteriormente durante la vigencia del mismo y comprobar en todo momento del desarrollo del contrato su cumplimiento en la forma establecida en el mismo.

A este respecto, nada se ha acreditado, ni siquiera aportado, en relación con medidas ex post (esto es, posteriores a la incorporación de los datos por parte del encargado del tratamiento) tendentes a comprobar la exactitud o veracidad de los datos. La única afirmación al respecto, contenida en las alegaciones a la propuesta de resolución es la siguiente:

“Derivado de lo anterior, cabe concluir que XFERA sí ejerció un control y una supervisión respecto de la actuación de FULLCARGA y de los puntos autorizados por ésta, contando con controles tendentes a garantizar la exactitud de los datos recabados, sin que quepa exigir la infalibilidad de estos.”

Pero no aclara, ni mucho menos justifica, cuáles serían esos controles.

En relación con este aspecto, procede traer a colación el contenido de la STS 1562/2020, de 15 de junio de 2020, rec. 601/2019, que señala lo siguiente:

“En tal sentido, ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2004, que confirma, en casación para Unificación de Doctrina, la de esta AN de 16 de octubre de 2003, haciéndose eco de lo argumentado por esta Sala refiere la diferenciación de dos responsables en función de que el poder decisión vaya dirigido al fichero o al propio tratamiento de datos. Así, el responsable del fichero es quien decide la creación del fichero y su aplicación, y también su finalidad, contenido y uso, es decir, quien tiene capacidad de decisión sobre la totalidad de los datos registrados en dicho fichero. El responsable del tratamiento, sin embargo, es el sujeto al que cabe imputar las decisiones sobre las concretas actividades de un determinado tratamiento de datos, esto es, sobre una aplicación específica. Se trataría de todos aquellos supuestos en los que el poder de decisión debe diferenciarse de la realización material de la actividad que integra el tratamiento. Con ello, como asimismo argumenta la STS de 26 de abril de 2005 (casación para unificación de doctrina 217/2004), el legislador español pretende adaptarse a las exigencias de la Directiva 95/46/CE, que tiene como objetivo dar respuesta legal al fenómeno, que cada vez es más frecuente, de la llamada externalización de los servicios informáticos, donde actúan múltiples operadores, muchos de ellos insolventes, creados con el objetivo de buscar la impunidad o irresponsabilidad de los que le siguen en los eslabones siguientes de la cadena. En la actualidad, el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y de aplicación directa a partir del 25 de mayo de 2018) distingue asimismo entre las figuras del responsable y del encargado del tratamiento. La primera se define en el apartado 7) del artículo 4 como " persona física o jurídica (...) que determine los fines y medios del tratamiento". Y el encargado de tratamiento en el apartado 8) del mismo artículo 4 como aquel que "trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento".

Ello en relación con los Artículos 24 y 28 del mismo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Responsable y encargado del tratamiento de datos que, sin lugar a duda, resultan asimismo responsables de las infracciones en materia de protección de datos, en tal nuevo marco normativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 82.2 del repetido Reglamento (UE) 2016/679 a

cuyo tenor: Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla lo dispuesto por el presente Reglamento. Un encargado únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya cumplido con las obligaciones del presente Reglamento dirigidas específicamente a los encargados o haya actuado al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable. Se desprende de todo lo anterior que la concurrencia, en el presente supuesto, de un encargado del tratamiento ZZZZ en absoluto exime de responsabilidad a la entidad XXXX ahora recurrente, y ello a pesar de la contundencia de las cláusulas que figuran en el contrato y anexo al mismo firmados por ambas compañías (hechos probados 9 y 10) en cuanto los datos personales tratados lo fueron con la finalidad de llevar a cabo una campaña publicitaria respecto de seguros de coche y moto que comercializaba la (XXXX), en definitiva en beneficio de dicha XXXX, siendo tal entidad actora la que, en último término, determina los fines y medios del repetido tratamiento de datos, por lo que la misma no puede ser exonerada de responsabilidad”.

Continúa la STS, en relación con la posible exoneración de responsabilidad alegada en cuanto a lo suscrito en el contrato de «encargado del tratamiento», lo siguiente:

“La conducta sancionada de obstaculización o impedimento por XXXX del ejercicio por su cliente del derecho de oposición al tratamiento de sus datos, se manifiesta en que dicha sociedad no adoptó ninguna clase de medida o de cautela para evitar el envío de publicidad a las direcciones de correo electrónico de su cliente por parte de aquellas empresas a las que encomendó la realización de las campañas publicitarias.

La adopción de las medidas o cautelas necesarias para asegurar la efectividad del derecho de oposición al tratamiento de sus datos por parte de XXXX, como responsable del fichero, subsisten aunque las campañas publicitarias no se realicen a partir de los datos de sus propios ficheros, sino con bases de datos de otras compañías contratadas por XXXX, y en este caso quedó acreditado que la recurrente no comunicó a las empresas con las que contrató la realización de servicios de publicidad la oposición del denunciante a recibir publicidad de la Mutua, ni en definitiva adoptó previsión alguna para asegurar la exclusión de su cliente de los envíos publicitarios contratados con terceras entidades.”

En lo que respecta a la aplicación del principio de culpabilidad en el ámbito del derecho sancionador regulado por el RGPD, la entidad investigada trae a colación la doctrina sentada por la STJUE, de 5 de diciembre de 2023 (asunto C-807/21, *Deutsche Wohnen SE y Staatsanwaltschaft Berlin*).

Pues bien, cabe preguntarse entonces cuáles son los parámetros de la diligencia debida que la entidad investigada debía haber observado en relación con la conducta examinada. La respuesta es que la diligencia que debió observar es la que era precisa para cumplir las obligaciones que le imponen los artículos 5.2, 24 y 25 del RGPD, a la luz de la doctrina de la Audiencia Nacional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Es plenamente aplicable al caso la SAN de 17 de octubre de 2007 (rec. 63/2006), que, después de referirse a que las entidades en las que el desarrollo de su actividad conlleva un continuo tratamiento de datos de clientes y terceros han de observar un adecuado nivel de diligencia, dice:

“[...] el Tribunal Supremo viene entendiendo que existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el infractor no se comporta con la diligencia exigible. Y en la valoración del grado de diligencia ha de ponderarse especialmente la profesionalidad o no del sujeto, y no cabe duda de que, en el caso ahora examinado, cuando la actividad de la recurrente es de constante y abundante manejo de datos de carácter personal ha de insistirse en el rigor y el exquisito cuidado por ajustarse a las prevenciones legales al respecto”.

A mayor abundamiento, la Audiencia Nacional en materia de protección de datos de carácter personal, ha declarado que *“basta la simple negligencia o incumplimiento de los deberes que la Ley impone a las personas responsables de ficheros o del tratamiento de datos de extremar la diligencia...”* (Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de junio de 2001).

En consecuencia, las alegaciones deben ser desestimadas toda vez que la entidad investigada ha infringido las obligaciones impuestas en el RGPD en calidad de responsable de los tratamientos llevados a cabo en su nombre y por su cuenta, en relación con las responsabilidades que exige a todo responsable del tratamiento el artículo 24 del RGPD. Las alegaciones no desvirtúan el contenido esencial de la infracción que se declara cometida ni suponen causa de justificación o exculpación suficiente.

Al respecto, y específicamente en relación con el principio de exactitud, cabe también recordar que la Audiencia Nacional, en su sentencia de 1 de marzo de 2024, rec. 1757/2021, dispone que *se impone al responsable del tratamiento que verifique la exactitud de los datos del interesado a través de la implementación de las medidas adecuadas cuando se efectúe una contratación. Precisamente por eso, es necesario asegurarse que la persona que contrata es quien realmente dice ser y deben adoptarse las medidas de prevención adecuadas para verificar la identidad de una persona cuyos datos personales van a ser objeto de tratamiento, y a ello obedece la exigencia de documentación identificativa, como viene reiterando la Sala entre otras en Sentencias de 3 de octubre 2013 (Rec. 54/2012), 21 de noviembre 2014 (Rec. 45/2014), entre otras. Obligación que es trasladable a los supuestos de representación, en que no solo es necesario comprobar los datos del interesado sino también los del representante que está actuando en nombre del representante y su efectiva representación.*

Por consiguiente, se desestima la alegación relativa a falta de culpabilidad de la parte reclamada en la comisión de la infracción imputada. La responsabilidad última sobre el tratamiento sigue estando atribuida al responsable, que es quien determina la existencia del tratamiento y su finalidad. Así, recordemos que, con carácter general los operadores son responsables del tratamiento de los datos de sus clientes, En este sentido, XFERA ha suscrito un contrato con FULLCARGA, uno de cuyos puntos de

venta ha realizado la venta de las tarjetas telefónicas correspondiente a las líneas objeto de la presente reclamación y en cuyo proceso debieran haberse garantizado el cumplimiento de todas las obligaciones legales de aplicación; entre ellas, el cumplimiento con el principio de exactitud de los datos previsto en el art. 5.1 d) del RGPD.

Esta falta de mecanismos adecuados nos lleva a rechazar de igual forma la alegación referida a la falta de afectación directa a un interesado identificado, por cuanto la conducta revelada pone de manifiesto cierta negligencia en el establecimiento de controles tendentes a garantizar la exactitud de los datos recabados por la parte reclamada. Se vulneró el principio de exactitud; el DNI que XFERA indica como correspondiente a **D.D.D.** corresponde a otra persona. Por tanto a ese DNI que pertenece a una persona identificada se le asocio un nombre y apellidos que no le corresponde y probablemente la titularidad de una línea que no es suya. La misma situación se ha producido con **B.B.B.**, al que se ha atribuido un DNI que no solo no es el suyo, sino que, conforme aclara el informe de la Agencia Tributaria, ni siquiera existe.

El informe del Ministerio del Interior

La parte reclamada menciona un informe emitido por el Ministerio del Interior durante la tramitación por la SETID por presunto incumplimiento, también por XFERA MÓVILES, de sus obligaciones de conservación de datos de la Ley 25/2007, de 18 de octubre. En el informe se contienen afirmaciones como:

- *“...el libro-registro se encuentra situado en las dependencias de dicho punto de venta, siendo la responsabilidad de su cumplimentación del punto de venta”;*
- *“Es responsabilidad del punto de venta comprobar visualmente el documento acreditativo que aporte la persona contratante” y*
- *“(no existe obligación de guardar una fotocopia del DNI), la operadora nunca puede comprobar la veracidad de los datos trasladados por los puntos de venta, por lo que la responsabilidad última de las infracciones siempre debe recaer en dichos puntos”*

Al respecto no podemos olvidar que estas afirmaciones se enmarcan dentro de la imputación a XFERA por la presunta vulneración de sus obligaciones de conservación de datos por la Ley 25/2007. Y en ese marco cobra todo el sentido lo afirmado, como que la recolección de datos se produce presencialmente en el establecimiento de venta, que la responsabilidad de dicha recolección es del titular de dicho establecimiento y que la operadora no puede comprobar la veracidad de lo trasladado

Sin embargo, en el presente expediente sancionador nos encontramos dentro de la comprobación de las obligaciones que el responsable del tratamiento (en este caso XFERA como se ha argumentado en el apartado anterior) tiene como garante de la exactitud de los datos conservados que, insistimos, se guardan para que en caso de ser necesarios sean puestos a disposición de las Fuerzas y cuerpos de seguridad dentro de las investigaciones penales por delitos graves.

Y a estos efectos, si bien es cierto que la toma de datos se produce por el encargado del tratamiento (una decisión como también se ha explicado antes voluntariamente adoptada por el responsable, que también podía optar por realizar dicha toma con medios propios) no lo es menos que dicho responsable es el obligado a garantizar el cumplimiento del principio de exactitud. Y tiene a su disposición medios tanto preventivos como reactivos para que dicha garantía se cumpla. Lo que no ha acreditado en este caso.

3. Inexactitud de los datos

Posibilidad de comprobación

En relación con la comprobación de la exactitud de los datos, se afirma por parte de XFERA que por su parte resultaría imposible comprobar la veracidad de los datos aportados. En este sentido afirma:

- La toma de datos materialmente se realiza por el responsable del tratamiento
- Este tiene impuesta la obligación, por contrato, de comprobar la identidad que figura en el documento identificativo y trasladarla a la base de datos
- Conforme al principio de minimización del art 5.1.c RGPD no puede conservarse una copia o imagen del documento identificativo.
- El operador no tiene modo de comprobar si los datos son exactos

Basándose en esas premisas, XFERA afirma que no tendría ningún medio a su disposición para realizar una comprobación de la veracidad de los datos. En sentido contrario, la conclusión es que debe conformarse con dar por buenos los datos que se cargan en la base de datos y no podría realizar comprobación alguna.

Incluso aceptando estas premisas, hay que tener en cuenta los resultados arrojados por la consulta de la Inspección de esta Agencia a los datos de la Agencia Tributaria. Respecto a una de las líneas telefónicas el resultado fue que el DNI proporcionado no se correspondía con el nombre y apellidos proporcionados. Pero es que respecto a la otra línea se proporcionó un número de DNI inexistente, es decir, que no se correspondía con ninguna persona.

A este respecto, se observa que XFERA no tenía establecido ningún mecanismo de seguridad conforme al cual no podrían aceptarse números de DNI inexistentes. Pero no solo eso, sino que como se ha explicado en relación con la responsabilidad de encargado o responsable, no consta aportado ningún mecanismo de control, auditoría, muestreo o similar que permitiese la posible existencia de errores o inexactitudes en los datos.

Es decir, tal y como reconoce XFERA, su labor en este asunto, como responsable del tratamiento, era dar por bueno todos y cada uno de los datos introducidos por sus

encargados del tratamiento, sin realizar comprobación alguna. Ello a sabiendas, según también se reconoce, que puede haber fraudes, suplantaciones e incluso delitos de falsedad documental con objeto de dar de alta titulares inexactos, lo que, también insistimos, puede dar lugar al fracaso de investigaciones penales.

Como se indicó anteriormente, la única afirmación que se contienen en las alegaciones de la parte reclamada, en relación con un posible control ex post de los datos conservados, sería la siguiente:

“Derivado de lo anterior, cabe concluir que XFERA sí ejerció un control y una supervisión respecto de la actuación de FULLCARGA y de los puntos autorizados por ésta, contando con controles tendentes a garantizar la exactitud de los datos recabados, sin que quepa exigir la infalibilidad de estos.”

Pero no menciona en qué medidas se concretaría este control, ni mucho menos se justifica documentalmente.

En el presente procedimiento no se sanciona solo por la mera producción de un resultado, como afirma XFERA, (sería un caso de responsabilidad objetiva proscrita por nuestro ordenamiento y el derecho sancionador), sino porque ese resultado de datos inexactos viene precedido por la ausencia de medidas técnicas y organizativas que hacen que concurra en este caso una grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones como responsable del tratamiento de datos personales.

El artículo 4 de la LOPDGDD

La parte reclamada invoca en su favor el artículo 4 de la LOPDGDD, que establece que:

“2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos:

a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado”

El interesado afirma la exclusión de responsabilidad en caso de que quien contrata la línea prepago facilite datos falsos. En primer lugar, nada ha quedado aclarado en relación con el verdadero origen de la inexactitud de los datos, ya que la parte reclamada se limita a repetir que no tienen manera de comprobar los datos que fueron introducidos por su encargado de tratamiento.

Pero, en segundo lugar, no puede obviarse que el primero de los párrafos reproducidos contiene el inciso *“siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen, sin dilación, la inexactitud de los datos personales”*. Y esta es la clave de este incumplimiento, que XFERA no tenía adoptadas medidas que tendiesen a comprobar la exactitud de los datos. Hasta el extremo que, como ha quedado acreditado, uno de los números de DNI aportado ni siquiera existe.

En su lugar, XFERA se limita a afirmar que tiene que dar por buenos los datos incorporados por su encargado, sin posibilidad alguna de comprobarlos. Y, no olvidemos, esta obligación de conservación tiene como finalidad que posteriores posibles investigaciones penales puedan tener éxito.

3. Proporcionalidad de la sanción

Las alegaciones de la parte reclamada discrepan en las circunstancias de graduación de la cuantía tenidas en cuenta en la propuesta de resolución. Ello en dos aspectos, primero rechazando circunstancias que agravarían la cuantía y segundo proponiendo otras que, a su juicio, la atenuarían

Circunstancias tenidas en cuenta en la propuesta y objetadas por XFERA.

En primer lugar, en opinión de XFERA, no existe intencionalidad o negligencia en la infracción, por su imposibilidad de comprobar la veracidad de los datos trasladados por los puntos de venta.

A este respecto cabe afirmar todo lo contrario a lo indicado por XFERA. De la instrucción del procedimiento se ha acreditado la inexistencia de controles reales en la actividad del encargado del tratamiento. La parte reclamada no ha aportado ninguna medida de control más allá del establecimiento formal de un contrato de servicios, unido a uno de encargo, en el que se impone al encargado la obligación de identificar a los usuarios de tarjetas prepago, sin que la información suministrada por este sea objeto de ningún tipo de comprobación o control posterior. Ello ha traído como consecuencia que, tal y como se declara en los hechos probados, conforme a la información aportada por la Agencia Tributaria, a uno de los números de DNI facilitados por XFERA no se corresponden ninguna persona, es decir se trataba de un número de DNI inexistente. Asimismo, el DNI que indicó como correspondiente a una persona, en realidad se corresponde con otra.

En sus alegaciones a la propuesta de resolución, la parte reclamada añade que, si bien la gravedad de la infracción se concreta en las dificultades que pueden producirse a la hora de identificar la realización de llamadas comerciales que alegaba la parte reclamante agrava la supuesta negligencia de XFERA. En relación con esto, alega que las obligaciones de XFERA como operadora de telecomunicaciones no abarcan el contenido o finalidades que los emisores de las llamadas puedan hacer de estas, motivo por el que no resulta imputable o vinculable a esta parte, a ningún nivel, la realización de estas.

Es evidente que no puede hacerse a XFERA responsable del contenido de las llamadas. Pero en lo que hace énfasis la propuesta de resolución sobre la que se alega, es que la falta de conservación de unos datos exactos y correctos tuvo como consecuencia que esta Agencia no pudiera sancionar una posible infracción consistente en la realización de llamadas comerciales sin base legitimadora. Con ello, cierto es que XFERA no es responsable del contenido de ninguna llamada, pero sí lo es de no conservar datos adecuados y exactos, lo que, de haberse producido, habrían permitido a esta Agencia determinar el sujeto responsable de una posible infracción

administrativa de su competencia. Ello por no mencionar que lo mismo habría sucedido si los datos de identidad del titular hubiesen sido requeridos por un juez para la determinación de la posible responsabilidad de un delito penal.

Aparte, discrepa la parte reclamada en que se haya considerado la conurrencia de una negligencia grave. Teniendo en cuenta, a juicio de XFERA, que no podía realizar comprobaciones de la veracidad de los datos aportados, se estaría produciendo un supuesto de “responsabilidad objetiva” o por el resultado.

A este respecto, analizada la concurrencia de la apreciación de una circunstancia como la negligencia grave prevista en la propuesta de resolución, se aprecia que el motivo de dicha concurrencia es similar al argumento principal utilizado a lo largo de esta resolución para la imputación de la infracción, esto es, la ausencia de controles sobre la actividad del encargado, y sobre los datos resultantes de las contrataciones por este. De este modo, no queda suficientemente justificada la consideración de esta circunstancia en la graduación de la sanción, ya que forma parte de la motivación sustancial de la imputación. Con ello, se considera que no procede aplicar a esta infracción la circunstancia de concurrencia de negligencia grave y se reduce la cuantía de la sanción conforme se detalla en el Fundamento octavo de esta resolución.

También objeta la parte reclamante a la inclusión de la agravante de vinculación con el tratamiento habitual de datos personales. Indica que esta agravante no podría aplicarse de manera genérica, sino relacionada con el tipo de tratamiento al que se refiere este expediente.

Y así se hace. Conforme a la disposición adicional única de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, los operadores que comercialicen tarjetas prepago de telefonía tienen la obligación de conservar los datos establecidos en dicha disposición respecto a todos y cada uno de los clientes que las contraten. Con ello, este tipo de tratamiento forma parte de la actividad habitual y diaria. Cada vez que se produzca una contratación, surge la obligación, como decimos para todos los clientes. Resulta difícil objetar que XFERA sea un sujeto respecto de cual se produce una “vinculación con el tratamiento habitual de datos personales”, circunstancia prevista en el artículo 76 de la LOPDGDD.

Circunstancias no contempladas y que, a juicio de XFERA, atenuarían su responsabilidad

En primer lugar afirma que no habría sido tomado en consideración la falta de daño efectiva a un interesado

A este respecto cabe precisar que en este procedimiento no ha establecido como criterio agravante la existencia de daño a un interesado. No obstante, la ausencia del mismo tampoco puede ser considerada como atenuante. Además, debe tenerse en cuenta que, en la investigación realizada en este procedimiento, la ausencia de datos exactos por parte de la parte reclamada, impidió investigar adecuadamente la infracción inicialmente denunciada.

Alegan que cuentan con una adhesión al Código de Conducta de Autocontrol para el "Tratamientos de datos en la actividad publicitaria", aprobado por la AEPD._

Tampoco cabe apreciar como atenuante esta circunstancia, toda vez que la mera adhesión formal al código de conducta no tiene trascendencia alguna en el supuesto enjuiciado. Recordemos que se sanciona por el tratamiento de datos inexactos y no por la realización de actividades publicitarias, por más que la reclamación inicial se refiriera a estas últimas.

No habría obtención de beneficio derivado de la conducta presuntamente infractora

Las sanciones deberán ser en cada caso individual efectivas, proporcionadas y disuasorias, conforme a lo previsto en el artículo 83.1 del RGPD. Admitir la ausencia de beneficios como una atenuante, no solo es contrario a los presupuestos de hechos contemplados en el artículo 76.2.c) LOPDGDD, sino también contrario a lo establecido en el artículo 83.2.k) del RGPD y a los principios señalados.

Así, valorar la ausencia de beneficios como una atenuante anularía el efecto disuasorio de la multa, en la medida en que minora el efecto de las circunstancias que inciden efectivamente en su cuantificación, reportando al responsable un beneficio al que no se ha hecho merecedor. Sería una rebaja artificial de la sanción que puede llevar a entender que infringir la norma sin obtener beneficios, financieros o del tipo que fuere, no le producirá un efecto negativo proporcional a la gravedad del hecho infractor.

La Sentencia de la Audiencia Nacional, de 05/05/2021, rec. 1437/2020, indica: "Considera, por otro lado, que debe apreciarse como atenuante la no comisión de una infracción anterior. Pues bien, el artículo 83.2 del RGPD establece que debe tenerse en cuenta para la imposición de la multa administrativa, entre otras, la circunstancia "e) toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento". Se trata de una circunstancia agravante, el hecho de que no concurra el presupuesto para su aplicación conlleva que no pueda ser tomada en consideración, pero no implica ni permite, como pretende la actora, su aplicación como atenuante"; aplicado al supuesto enjuiciado, la falta del presupuesto para su aplicación respecto del art. 76.2.c) de la LOPDGDD, esto es, obtener beneficios consecuencia de la infracción, no permite su aplicación como atenuante.

Asimismo, se alegan el "espíritu colaborativo" demostrado durante la actuación investigadora de la AEPD.

No puede considerarse como atenuante el cumplimiento de un deber legal, toda vez que, conforme al artículo 52 de la LOPDGDD, los sujetos investigados deben prestar la colaboración requerida a la inspección de la AEPD.

Por lo tanto, y en atención a lo reflejado en los apartados anteriores, procede desestimar las alegaciones presentadas.

Finalmente, por el mismo motivo, esto es que de apreciarse en sentido positivo constituirían agravantes pero no son atenuante si no concurren, permiten desestimar factores como:

- El bloqueo de línea telefónica cuando se comprobó la inexactitud del dato,
- El no tratamiento de categorías especiales de datos personales

I. Práctica de prueba propuesta

A continuación, se contesta a la prueba propuesta por la parte reclamada:

1. Documental, consistente en la unión al procedimiento de los documentos aportados con este escrito.

Se aceptó y unió al expediente.

2. Más documental, consistente en que esta digna Agencia libre atento oficio a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, a efectos de solicitar copia del expediente sancionador SAN00067/23, en el marco del cual se dictó la resolución aportada junto al escrito de alegaciones;

A este respecto, analizada la resolución aportada por la parte reclamada, se observa que esta decreta el archivo de procedimiento sancionador inicialmente abierto a XFERA por su presunto incumplimiento de las obligaciones de identificación de titulares de tarjetas prepago conforme a la Ley 25/2007.

El archivo se basa en el informe emitido por el Ministerio del Interior en el que se contienen afirmaciones como:

“Es responsabilidad del punto de venta comprobar visualmente el documento acreditativo que aporte la persona contratante del servicio antes de apuntar dicha información en el libro registro para comprobar su veracidad”

“Este Grupo es conocedor de que la operadora de comunicaciones tiene procedimientos automáticos y manuales para la lucha contra el fraude.”

A este respecto, procede rechazar la práctica propuesta por dos motivos: primero, porque su práctica no alteraría el resultado de este expediente, toda vez que va referido a la responsabilidad del operador o distribuidor por el cumplimiento de la propia Ley 25/2007, y no incide en aspectos relativos a la protección de datos y a la peculiar relación existente entre responsable y encargado conforme se motiva en esta resolución.

Y segundo porque, con independencia del motivo anterior, ya consta en el expediente, aportada por la propia parte reclamada, la resolución que contiene los criterios que la misma pretende que se apliquen al presente procedimiento sancionador.

3. Testifical por escrito, consistente en esta Agencia libre oficio a FULLCARGA IBÉRICA, S.L., a efectos de que su representante legal conteste a las siguientes preguntas:

*a. ¿Fueron comercializadas, a través de su plataforma informática, dos tarjetas prepago de la marca “Lebara”, correspondientes a las líneas móviles ***TELÉFONO.4 y ***TELÉFONO.2, los días 23 de febrero de 2022 y 3 de marzo de 2022, respectivamente?*

b. En caso afirmativo, ¿pueden confirmar qué concreto establecimiento, de los adheridos a su red, comercializó las citadas tarjetas prepago?

c. ¿Facilita Fullcarga algún tipo de instrucciones, a los establecimientos adheridos a su red, sobre cómo cumplimentar los datos de los adquirentes de tarjetas prepago de telefonía móvil, a efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de identificación previstas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre?

Procede rechazar esta prueba, en tanto su práctica en nada alteraría el resultado de este procedimiento sancionador. En efecto, en los hechos probados de esta propuesta ya se recoge cuál fue el procedimiento de contratación e identificación de clientes en este supuesto, a través del distribuidor FULLCARGA IBÉRICA. Ello no obstante, tal y como se motiva en esta propuesta, la atribución de la infracción, procede, en aplicación del régimen previsto en el RGPD, al responsable del tratamiento.

II. Obligación. Artículo 5.1 d) RGPD

El Artículo 5 del RGPD, Principios relativos al tratamiento, dispone que

1. Los datos personales serán:

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);

En relación con el artículo 5.1.d), dicho precepto exige que se adopten “las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan”. En este sentido, la Audiencia Nacional señalaba en su sentencia de 27/02/2008, Recurso 210/2007, “... El principio de veracidad o exactitud tiene gran relevancia, en cuanto no sólo resulta necesario que los datos se recojan para su tratamiento de acuerdo con una serie de criterios (principio de proporcionalidad) y que los mismos se empleen para finalidades compatibles a las que motivaron la recogida (principio de finalidad), sino que también exige que quien recoge y trata datos de carácter personal garantice y proteja que la información sometida a tratamiento no sea inexacta y esté puesta al día. El incumplimiento o vulneración del principio de veracidad puede tener importantes consecuencias para el afectado...>>”. Asimismo, el artículo 5.1.d) no impone adoptar medidas desproporcionadas para actualizar los datos, sino las razonables, atendiendo a los medios disponibles y el fin para el que se usan los datos. Así lo expresa también el considerando 39 del RGPD.

(...) Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos. (...)

La SAN de 1 de marzo de 2024 (RCA 0001757/2021) dispone que «En esta línea la STS de 13 de diciembre 2021 (Rec. 6109/2020) establece que "(...) es exigible a dicha empresa contratante, como diligencia necesaria para que no se le pueda reprochar el incumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal -tanto en lo que se refiere a la exigencia de consentimiento del interesado como en lo relativo al principio de veracidad y exactitud la implantación de medidas de control y verificación tendentes a asegurar que la persona que pretende contratar es quien dice ser, esto es, que coincide con el titular del DNI aportado"

Así se impone al responsable del tratamiento que verifique la exactitud de los datos del interesado a través de la implementación de las medidas adecuadas cuando se efectúe una contratación. Precisamente por eso, es necesario asegurarse que la persona que contrata es quien realmente dice ser y deben adoptarse las medidas de prevención adecuadas para verificar la identidad de una persona cuyos datos personales van a ser objeto de tratamiento, y a ello obedece la exigencia de documentación identificativa, como viene reiterando la Sala entre otras en Sentencias de 3 de octubre 2013 (Rec. 54/2012), 21 de noviembre 2014 (Rec. 45/2014) etc.»

Por lo tanto, atendiendo a las circunstancias del presente procedimiento sancionador cabe afirmar que la parte reclamada ha incumplido la obligación prevista en el mencionado art. 5.1 d)

Así, como queda constatado en los hechos probados, según la información aportada por la Agencia Tributaria, la búsqueda por el DNI facilitado por XFERA como correspondiente a **B.B.B.** no proporciona resultados. Asimismo, el DNI que XFERA indica como correspondiente a **D.D.D.** corresponde a otra persona.

III. Tipificación y calificación de la infracción

De conformidad con las evidencias de las que se dispone, se considera que los hechos conocidos son constitutivos de una infracción, imputable a la parte reclamada tipificada en el artículo 83.5 del RGPD que estipula lo siguiente:

"5. Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:

a) *los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9;"*

A efectos del plazo de prescripción de las infracciones, la infracción imputada prescribe a los tres años, conforme al artículo 72.a). de la LOPDGDD, que califica de muy grave la siguiente conducta:

“a) El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679.”

I. Sanción

Esta infracción puede ser sancionada con multa de 20 millones de euros como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía, de acuerdo con el artículo 83.5 del RGPD.

Asimismo, se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con los siguientes criterios que establece el artículo 83.2 del RGPD:

- a) la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido;*
- b) la intencionalidad o negligencia en la infracción;*
- c) cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados;*
- d) el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32;*
- e) toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento;*
- f) el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;*
- g) las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción;*
- h) la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida;*
- i) cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas;*
- j) la adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación aprobados con arreglo al artículo 42, y*
- k) cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción.*

En el presente supuesto se considera que concurren las siguientes circunstancias:

- La naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido [artículo 83.2.a) RGPD]. Hay que tener en cuenta que la inexactitud del dato transmitido a la AEPD ha obstaculizado la averiguación de una posible infracción administrativa.

- La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos personales (artículo 76.2, letra b), de la LOPDGDD): XFERA, como consecuencia de su actividad empresarial realiza de forma habitual y continua tratamientos de datos de carácter personal de un elevado número de interesados. La prestación de servicios de comunicaciones electrónicas al público es la actividad principal de XFERA, implica forzosamente operaciones de tratamiento de datos personales de las personas físicas clientes (o potenciales clientes) de dicha entidad, no únicamente respecto a la documentación remitida por estos por los canales establecidos por la responsable sino para todo tipo de actividades. Así, la infracción se produce en el marco de un tratamiento de datos personales que habitualmente realiza el responsable en su negocio y que se encuentra estrechamente vinculado a este.

Como se ha indicado en el Fundamento cuarto, punto 5, de esta resolución, se descarta la concurrencia de la circunstancia de negligencia grave que fue tenida en cuenta en la propuesta de resolución. Con ello, y con la apreciación de las circunstancias detalladas más arriba, se estima procedente reducir la cuantía de la sanción a SETENTA MIL EUROS (70.000€)

I. Adopción de medidas

Se acuerda imponer al responsable la adopción de medidas adecuadas para ajustar su actuación a la normativa mencionada en este acto, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 58.2 d) del RGPD, según el cual cada autoridad de control podrá *“ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, de una determinada manera y dentro de un plazo especificado...”*. La imposición de esta medida es compatible con la sanción consistente en multa administrativa, según lo dispuesto en el art. 83.2 del RGPD.

En concreto, se ordena que, en el plazo de 6 meses, XFERA introduzca los procedimientos y mecanismos necesarios de comprobación de la identidad de los clientes que adquieran una tarjeta en modalidad prepago.

Se advierte que no atender la posible orden de adopción de medidas impuestas por este organismo en la resolución sancionadora podrá ser considerado como una infracción administrativa conforme a lo dispuesto en el RGPD, tipificada como infracción en su artículo 83.5 y 83.6, pudiendo motivar tal conducta la apertura de un ulterior procedimiento administrativo sancionador.

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de graduación de las sanciones cuya existencia ha quedado acreditada, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos

RESUELVE:

PRIMERO:

IMPONER a **XFERA MÓVILES, S.A.U.**, con NIF **A82528548**, por una infracción del artículo 5.1.d) del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD, una multa de 70.000,00 euros (SETENTA MIL euros).

SEGUNDO:

ORDENAR a **XFERA MÓVILES, S.A.U.**, con NIF **A82528548**, que en virtud del artículo 58.2.d) del RGPD, en el plazo de 6 meses desde que la presente resolución sea firme y ejecutiva, acredite haber procedido al cumplimiento de las medidas establecidas en el fundamento de derecho noveno de esta resolución

TERCERO:

NOTIFICAR la presente resolución a **XFERA MÓVILES, S.A.U.**.

CUARTO:

Esta resolución será ejecutiva una vez finalice el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición (un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución) sin que el interesado haya hecho uso de esta facultad. Se advierte al sancionado que deberá hacer efectiva la sanción impuesta una vez que la presente resolución sea ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), en el plazo de pago voluntario establecido en el art. 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso, indicando el NIF del sancionado y el número de procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento, en la cuenta restringida nº **IBAN: ES00-0000-0000-0000-0000-0000 (BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX)**, abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en la entidad bancaria CAIXABANK, S.A.. En caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo.

Recibida la notificación y una vez ejecutiva, si la fecha de ejecutividad se encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el

día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

938-100325

Lorenzo Cotino Hueso
Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos